

2022

المسؤولية التقصيرية

السنة الأولى ماستر – العقود و المسؤولية

د/ مسعود بور غدة نريمان



مقدمة في المسؤولية التقصيرية

تصطدم حرية في التصرف بحاجز منيع وهو عدم الإضرار بالغير. وبمجرد تجاوز هذه الحدود، فإنه يتحمل تبعه ذلك، أي أنه يكون مسؤولاً عن ذلك التجاوز. فالمسؤولية إذن هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلاً يستوجب المؤاخذه.

والمسؤولية القانونية على أنواع، أما أن تكون أخلاقية أو قانونية، والمسؤولية القانونية إما أن تكون جزائية أو مدنية، والمسؤولية المدنية إما أن تكون عقدية أو أن تكون تقصيرية.

فالمسؤولية الأخلاقية تقوم في مواجهة الشخص الذي يخل بالتزام تفرضه عليه قواعد الأخلاق، أما المسؤولية القانونية فهي تواجه الشخص الذي يخل بالتزام قانوني.

الفرع الأول: تمييز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية :

تقوم المسؤولية الجزائية عند إخلال الشخص بقاعدة من قواعد قانون العقوبات، أو أي نص جزائي خاص آخر. أما المسؤولية المدنية فتقوم في مواجهة الشخص الذي يخل بالتزام يفرضه عليه القانون مسبباً بسلوكه ضرراً للغير وإفقار ذمته. وتعرف أيضاً بأنها وتختلف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية في نقاط عدة، أهمها:

✓ من حيث السبب: سبب المسؤولية الجزائية هو فعل ضار يلحق بالمجتمع، في حين أن سبب المسؤولية المدنية هو فعل ضار يلحق شخصاً من الأشخاص

✓ من حيث الأساس: أساس المسؤولية الجزائية هو إخلال بواجب منصوص عليه في قانون العقوبات، أو في قانون جزائي خاص، أما أساس المسؤولية المدنية فهو إخلال بواجب قانوني أو اتفاقي

✓ من حيث الجزاء: الجزاء في المسؤولية الجزائية هو إما عقوبة جزائية مانعة للحرية أو مقيدة للحرية أو غرامة مالية، وهو ينطوي على العقاب. أما الجزاء في المسؤولية المدنية فهو إصلاح و جبر الضرر الذي أصاب الضحية، وذلك بتعويض المضرور عن ذلك الضرر أما نقداً أو عينا

✓ الخطأ الجزائي محدد على سبيل الحصر، استناداً إلى القاعدة الدستورية التي تقول بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني نافذ وقت ارتكاب الفعل. أما الخطأ المدني فهو غير محدد

على سبيل الحصر، وانما يقاس على السلوك المعتاد للرجل العادي المميز، اذ كل انحراف عن هذا السلوك يوجب التعويض متى كان ضار. هذا ولما كانت المسؤولية المدنية لا تهتم الا بجير الضرر فقد تقوم هذه الاخيرة لمجرد وجود الضرر ولو لم يخطئ الشخص.

✓ من حيث التأمين على المسؤولية: لا يجوز التأمين على المسؤولية الجزائية، في حين أن التأمين جائز على المسؤولية المدنية حتى لو كان أساسها الخطأ. ولكن لا يجوز التأمين فيها على الخطأ العمدى أو الغش.

✓ من حيث التنازل والصلح: لا يجوز التنازل والصلح في المسؤولية الجزائية، في حين أنهما جائزان في المسؤولية المدنية، والسبب في ذلك أن الحق في المسؤولية الجزائية هو عام للمجتمع، أما الحق في المسؤولية المدنية فهو خاص لأشخاص.

✓ من حيث دعوى المسؤولية والاختصاص: الدعوى الناشئة عن المسؤولية الجزائية هي دعوى عامة وهي من حق المجتمع، ولكن تنوب النيابة العامة عنه في رفعها. وهي من اختصاص القضاء الجزائي. أما الدعوى الناشئة عن المسؤولية المدنية فهي خاصة ويملكها المضرور وحده، وهي في الاصل من اختصاص المحاكم المدنية.

وعلى الرغم من هذه الفروق بين المسؤوليةين، فقد تنشأ المسؤوليةان الجزائية و المدنية عن فعل واحد. وقد سبق القول بأن الخطأ المدني هو كل اخلال بالتزام قانوني . ويترتب على ذلك أن كل خطأ جزائي هو بالضرورة خطأ مدني، والعكس غير صحيح فليس كل خطأ مدني بالضرورة هو خطأ جزائي. فإذا أضر الفعل بالمجتمع وبأحد الأشخاص في أن واحد، فإنه يؤدي إلى نشوء المسؤوليةين معاً، كما في المتاجرة بالممنوعات. أو إذا أضر فعل بشخص وكان المشرع يعتبره خطراً بالنسبة للمجتمع أيضاً، كالسرقة والقتل. ويكون الفاعل في مثل هذه الحال مسؤولاً مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية في الوقت ذاته.

ويترتب على اجتماع المسؤوليةين نتائج هامة تتمثل في تأثير قواعد المسؤولية الجزائية على قواعد المسؤولية المدنية، ويبدو هذا التأثير من خلال النواح الآتية :

1- من حيث الاختصاص: يجوز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي . (م. 3 ق. ا.ج) لكن هذا لا يمنع من إقامة الدعوى المدنية، للمطالبة بالحق الشخصي، أمام القضاء المدني. ويجب على المحكمة المدنية، في مثل هذه الحال، أن توقف النظر في دعوى الحق الشخصي إلى أن تفصل دعوى الحق العام (م. 4 ق. ا.ج) ، وذلك تطبيقاً للقاعدة التي مفادها أن الجزائي يعقل المدني،

فاذا اختار المضرور الطريق المدني، وكان الطريق الجزائي مفتوحاً امامه، فلا يحق له الرجوع إلى الطريق الجزائي، لان الاصل هو الطريق المدني. أما إذا كان الطريق الجزائي مسدوداً، ثم فتح بعد ذلك فيحق للمضرور نقل دعواه إلى القضاء الجزائي. أما إذا رفع المضرور دعواه أمام القضاء الجزائي بداية، فيحق له الرجوع إلى القضاء المدني

2- من حيث حجية الحكم: يتمتع الحكم الجزائي بحجية في الدعوى المدنية، ولكن لا يرتبط القاضي المدني، بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم، أو في الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة. يتبين من ذلك أن الحكم الجزائي لا يتمتع بحجية في الدعوى المدنية الا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها، وكان فصله في هذه الوقائع ضرورياً. ويجب التمييز بين حالتين:

✓ صدور حكم بالإدانة: إذا صدر الحكم بإدانة المدعى عليه، فيتقيد القاضي المدني بهذا الحكم، وتقيد به هذا مقصور على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم الجزائي، وكان فصله فيها ضرورياً. ولكن القاضي المدني لا يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع. فلا يستطيع القاضي المدني في مثل هذه الحال أن يناقش مثل هذا الحكم، وعليه أن يحكم على المحكوم عليه جزئياً بالتعويض إذا كان فعله، الذي أثبت الحكم الجزائي بأنه يشكل جريمة وبأنه هو الذي ارتكبه، قد ألحق ضرراً بأحد الأشخاص.

ولا يجوز للقاضي المدني أن ينفي وجود الخطأ، إذا كان الحكم الجزائي أثبت وجوده. كما لا يجوز له أن يقرر بأن الخطأ غير متعمد، إذا كان الحكم الجزائي قد أثبت بأن خطأ المدعى عليه كان متعمداً.

أما إذا فصل القاضي الجزائي بوقائع لم تكن ضرورية للفصل في الدعوى الجزائية، فلا يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي بالنسبة لهذه الوقائع، كما لو قرر الحكم الجزائي بأن المدعى عليه هو الذي ارتكب الجرم، ولكن هذا الجرم لم يؤد إلى إلحاق الضرر بأحد الأشخاص. فهنا عندما فصل القاضي الجزائي في واقعة الضرر، فإن فصله فيها ليس ضرورياً للفصل في الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يتقيد القاضي المدني بهذه الواقعة. وكذلك الحال عندما يقوم القاضي الجزائي بتوزيع المسؤولية عن الحادث في حوادث السير، إذ لا يعد ذلك ضرورياً للفصل في الدعوى، إذ يكفي للمساءلة الجزائية في مثل هذه الحال ثبوت مخالفة قانون السير. وكذلك الحال إذا حدد الحكم الجزائي مبلغ الدين بين طرفي الدعوى، لأن الحكم في الدعوى الجزائية لا يتوقف على هذا التحديد.

وعلى العكس من ذلك فإن حكم القاضي المدني لا يتمتع بأي حجية أمام القاضي الجزائي، فإذا قرر الحكم المدني بإلزام المدعى عليه بالتعويض، فإن هذا الحكم لا يلزم القاضي الجزائي بالحكم بإدانة المدعى عليه.

✓ **صدور حكم بالبراءة:** إذا صدر الحكم الجزائي ببراءة المدعى عليه لعدم وجود الخطأ، أو لعدم نسبة الخطأ إليه، أو لأن المدعى عليه كان في حالة دفاع مشروع، فإن القاضي المدني يتقيد بالحكم الجزائي في مثل هذه الحال. أما إذا كان الحكم ببراءة المدعى عليه قد صدر لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل خطأ جزائياً، فلا يتقيد القاضي المدني بهذا الحكم، لأن هذا الفعل قد يشكل خطأ مدنياً، وقد سبق القول أنه ليس بالضرورة كل خطأ مدني هو خطأ جزائي. وكذلك الحال إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على عدم كفاية الأدلة، فلا يمنع على القاضي المدني البحث عن الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار.

وعلى العكس من ذلك فإن حكم القاضي المدني لا يتمتع بأي حجية أمام القاضي الجزائي، فإذا قرر الحكم المدني بإلزام المدعى عليه بالتعويض، فإن هذا الحكم لا يلزم القاضي الجزائي بالحكم بإدانة المدعى عليه. ويرى الفقه أن المحكمة المدنية لا تتقيد بالحكم الصادر بالبراءة في الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية بدون خطأ كما هو عليه الحال في مسؤولية حارس الأشياء غير الحية أو حارس الحيوان.

3.. من حيث التقادم: الأصل أن دعوى المسؤولية المدنية، وموضوعها المطالبة بالتعويض، تسقط بمرور خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، وذلك سواء أمام القضاء المدني (م. 133 ق.م.) أو الجزائي (م. 10 ق.ا.ج.).

وتسقط الدعوى الجزائية إذا كان الجرم جنائية بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجنائية، أو تاريخ آخر الإجراءات فيها (م. 7 ق.ا.ج.). أما إذا كان الجرم جنحة، بمرور 03 سنوات (م. 8 ق.ا.ج.)، وفي المخالفات تسقط بمرور سنة واحدة (م. 9 ق.ا.ج.).

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه و طبقاً للمادة 8 مكرر "لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنگ الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية. لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنگ المنصوص عليها في الفقرة أعلاه."

الفرع الثاني: نوعا المسؤولية المدنية: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية:

تقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين، وهما: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. وتنجم المسؤولية العقدية عن الإخلال بالتزام عقدي. وأما المسؤولية التقصيرية فهي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني سابق.

وقد أنقسم الفقه إلى تيارين بشأن التمييز بين هذين النوعين من المسؤولية المدنية من عدمه

أولا : نظرية ازدواج المسؤولية: ظهرت هذه النظرية في فرنسا بداية القرن التاسع عشر. و يرى أنصارها أنه هناك عدة فروق جوهرية بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية تستلزم التمييز بينهما نظرا لاختلاف الأحكام المطبقة على المسؤوليتين. وهذه الفروق بين المسؤوليتين هي الآتية:

1- من حيث الشروط:

- ✓ يشترط في المسؤولية العقدية أن يكون المتعاقد كامل الأهلية في معظم العقود، أما في المسؤولية التقصيرية فيكفي فيها أن يكون المسؤول متمتعاً بأهلية التمييز.
- ✓ يشترط في المسؤولية العقدية إعدا المدين من حيث المبدأ، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يشترط إعدا المسؤول فيها.
- ✓ يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على الإعفاء من المسؤولية العقدية أو على تخفيفها، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز ذلك

2- من حيث الإلثبات: يقع عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية على المضرور، وهو الدائن بالتعويض. أما في المسؤولية العقدية، فيقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود العقد، وعلى المدين عبء إثبات أنه نفذ التزامه العقدي.

3- من حيث مدى التعويض : يشمل التعويض في المسؤولية العقدية الضرر المباشر المتوقع وقت انعقاد العقد ولا يشمل الضرر غير المتوقع . أما في المسؤولية التقصيرية، فالتعويض يشمل الضرر المباشر المتوقع والضرر غير المتوقع.

4- من حيث التضامن: إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية قام التضامن بينهم بحكم القانون. أما في حال تعدد المسؤولين في المسؤولية العقدية فلا يفترض التضامن بينهم، وإنما لابد أن ينص العقد على ذلك.

5- من حيث التقادم: تتقادم المسؤولية التقصيرية بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الفعل الضار، أما المسؤولية العقدية فتتقادم بمرور خمس عشرة سنة من وقت ابرام العقد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ثانيا: نظرية وحدة المسؤولية: ظهرت هذه النظرية في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر، ومن أبرز أنصارها الفقيه بلانيول الذي يرى بأنه لا فرق بين المسؤوليتين من حيث الطبيعة، فكلتاهما تنشأ عن الإخلال بالتزام سابق، هو التزام عقدي في المسؤولية العقدية وهو التزام قانوني في المسؤولية التقصيرية. وبالتالي يرى أنصارها بأن الفروق التي استند إليها أنصار نظرية ازدواج المسؤولية فروق ظاهرية، ويفندونها على النحو الآتي:

1- بالنسبة للشروط:

✓ يرى أنصار هذه النظرية أنه ليس صحيحاً أنه يشترط في المسؤولية العقدية أن تتوافر أهلية الرشد في المتعاقد في معظم العقود، ويكتفى بأهلية التمييز في المسؤولية التقصيرية. في الحقيقة أهلية الرشد هي شرط لانعقاد العقد، وليس لقيام المسؤولية. وكذلك فإن أهلية التمييز هي شرط لنسبة الخطأ في المسؤولية التقصيرية إلى المسؤول. وبالتالي يرى أنصار هذه النظرية أن المسؤولية بنوعها لا تتطلب أي أهلية. وبالتالي فإذا كانت أهلية الرشد متوافرة في المتعاقد أثناء إبرام العقد، ثم زالت هذه الأهلية بعد ذلك فإنه يبقى ملزماً بتنفيذ التزاماته، وتبقى مسؤوليته قائمة على الرغم من زوال أهليته.

✓ أما بالنسبة للعذر، فليس صحيحاً أنه يشترط في المسؤولية العقدية وإنما الصحيح أن الأعذار يشترط في الالتزامات الإيجابية المتضمنة القيام بعمل ولا يشترط في السلبية المتضمنة الامتناع عن القيام بعمل. وبما أن الالتزام في المسؤولية التقصيرية هو دائماً امتناع عن القيام بعمل، أي التزام سلبي، لذلك لا يشترط فيها الأعذار. وكذلك فإنه لا يشترط في المسؤولية العقدية أيضاً في حال ما إذا كان الالتزام العقدي هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل، ولكنه بالمقابل يشترط إذا كان التزاماً بالقيام بعمل.

✓ أما بالنسبة لعدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية فسبب ذلك هو أن القانون نفسه منع هذا الإعفاء، ولم يمنع ذلك في المسؤولية العقدية إلا على سبيل الاستثناء.

2- بالنسبة للإثبات: يرى أنصار هذه النظرية أن عبء الإثبات في المسؤولية يقع على عاتق الدائن، وهو إثبات التزام السابق. ففي المسؤولية العقدية عليه إثبات العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة لإثبات الالتزام السابق، لأن القانون يفرضه على الجميع.

3- من حيث مدى التعويض: يرى أنصار هذه النظرية أن التعويض في المسؤولية العقدية لا يشمل الضرر المباشر غير المتوقع، وذلك لأن هذا الضرر لم يدخل في حساب المتعاقدين وبالتالي لم تتجه إليه إرادتهما عند التعاقد. وبالتالي فإن إرادة المتعاقدين وقت التعاقد هي التي تحدد مدى التعويض. أما في المسؤولية التقصيرية، فالقانون هو الذي يحدد مدى التعويض، لذلك فهو يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.

4- من حيث التضامن: القانون هو الذي يفرض التضامن بين المدينين في حال تعددهم في المسؤولية التقصيرية، والسبب في ذلك أن الفعل غير المشروع هو السبب في الضرر، فإذا اشترك شخصان أو أكثر في ارتكابه، كان منهم هو السبب في الضرر، وبالتالي يجب عليه تعويض الضرر كاملاً.

5- من حيث التقادم: اختلاف التقادم في المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية لا يعود إلى طبيعة المسؤولية وإنما إلى إرادة المشرع. لذلك لا يميز المشرع في بعض الدول بين المسؤوليةين من حيث التقادم

ثالثاً: موقف المشرع الجزائري من النظريتين:

✓ لقد ميز المشرع الجزائري بين المسؤوليةين العقدية والتقصيرية بصورة واضحة، حيث خص كل نوع من هاتين المسؤوليةين بأحكام خاصة بها. فالقانون المدني الجزائري يفرق بين العقد والعمل غير المشروع، وجعل كلاً منهما مصدراً مستقلاً للالتزام في الباب الأول من الكتاب الثاني، وعنون هذا الباب هو "مصادر الالتزام".

1. الاعذار: بالنسبة للمسؤولية العقدية تنص المادة 179 ق.م انه " لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك". أما بالنسبة للتقصيرية فتنبص المادة 181 ق.م انه "لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية: إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب عن عمل مضر"

2. مدى التعويض: بالنسبة للمسؤولية العقدية، فلا يعوز إلا الضرر المتوقع فتنبص المادة 182 انه "غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ

جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد". وبمفهوم المخالفة أما في المسؤولية التقصيرية فيشمل التعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.

3. من حيث التضامن: إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية كانوا، بموجب المادة 126 ق.م. متضامين في التزامهم بتعويض الضرر. أما في المسؤولية العقدية فلا يقوم التضامن بين المسؤولين في حال تعددهم الا بموجب اتفاق أو نص قانوني، وفقاً لما جاء في المادة 426 ق.م.

4. من حيث الاعفاء من المسؤولية: أجازت المادة 178 ق.م. الاعفاء من المسؤولية العقدية باستثناء حالة غش المدين أو خطئه الجسيم. في حين أن المادة ذاتها تمنع في الفقرة الثالثة منها الاعفاء من المسؤولية التقصيرية تحت طائلة البطلان المطلق.

✓ ومن جهة أخرى ، يلاحظ ان المشرع الجزائري أنه قطع شوطاً معتبراً في توحيد قواعد المسؤوليةيتين. بإدراجه مسؤولية المنتج في المادة 140 مكرر ق.م. ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية ولو جمعته بالمتضرر علاقة تعاقدية

رابعاً: الجمع والخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: في حال ما إذا توافرت في العمل الواحد شرائط المسؤولية العقدية وشرائط المسؤولية التقصيرية، فهل يجوز للمضرور الجمع بينهما أو الخيرة بينهما؟

1- الجمع بين المسؤوليةيتين: يجمع الفقه على عدم جواز الجمع بين المسؤوليةيتين بمختلف ، فلا يجوز للمضرور أن يطالب بتعويض الضرر الواحد مرتين، اذ سوف يؤدي ذلك إلى إثراء المضرور على حساب المسؤول دون سبب مشروع.

2- الخيرة بين المسؤوليةيتين: إذا كان الجمع بين المسؤوليةيتين ممنوع قطعاً وباجماع الفقهاء، فهل يجوز للمضرور أن يختار بين إحدى هاتين المسؤوليةيتين إذا كانت شرائطهما متوافرة؟ وهذه هي مسألة الخيرة بين المسؤوليةيتين. أنقسم الفقه وكذلك القضاء حول هذه المسألة بين مؤيد ومعارض ✓ يرى مؤيدو الخيرة أن شرائط كل من المسؤوليةيتين تختلف، وبالتالي إذا توافرت شرائط المسؤوليةيتين يحق للمضرور أن يختار بينهما، وبالتالي يمكن أن تطبق المسؤولية التقصيرية حتى في حال قيام عقد بين المسؤول والمضرر، شريطة أن تكون شرائط هذه المسؤولية متوافرة.

- كما يرى مؤيدو الخيرة أن المسؤولية التقصيرية هي من النظام العام، وبالتالي لا تجبها المسؤولية العقدية.

✓ أما خصوم الخيرة فيرون بأنه إذا توافرت شروط المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في العمل الواحد فإن المضرور لا يحق له الخيار بينهما، انما المسؤولية العقدية تحجب المسؤولية التقصيرية . وبالتالي تطبق في مثل هذه الحال قواعد المسؤولية العقدية. ويبررون ذلك بأن العلاقة بين المضرور والمسؤول مصدرها العقد، والدائن (المضرور) لا يعرف المدين (المسؤول) الا من خلال ذلك العقد. وبالتالي يجب أن يحكم العقد العلاقة بينهما. ومن جهة اخرى، فإن المسؤولية العقدية تترتب عن إخلال بالتزام العقد، والعقد شريعة المتعاقدين. وكل مساس بقواعد المسؤولية العقدية يترتب عنها المساس بمبدأ سلطان الإرادة الذي هو أصل التراضي في ميدان العقود. وبالتالي فإن المسؤولية التقصيرية لا يلتجأ إليها إلا في غياب العقد،

الفرع الثالث: تطور المسؤولية المدنية.

إن ما وصلت إليه المسؤولية المدنية من تطور في الوقت الحاضر في مختلف الأنظمة القانونية المعاصرة لم يأت دفعة واحدة بل ترسخ عبر مراحل تاريخية متتالية.

1. تميزت المرحلة الأولى بارتباط المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية واختلاطهما، فكانت تقوم على فكرة الثأر، حيث كان جزاء الفعل الضار متروكا للمضرور يثار بنفسه ممن أوقع به الضرر دون ضوابط الثأر، مما يؤدي إلى نزاع بين العشائر، فساد في القانون الروماني مبدأ العين بالعين، والأنف بالأنف. ومن ثم ظهرت بعد ذلك فكرة الدية الاختيارية ثم الالزامية، التي حلت محل الانتقام

2. وفي مرحلة ثانية أصبحت الدولة تميز بين نوعين من الجرائم، وهما: الجرائم الخاصة، ولا تملك الدولة حق العقاب فيها، وانما يقتصر تدخلها على فرض الدية المحددة على الجاني. والجرائم العامة، وتملك الدولة فيها بالاضافة إلى فرض الدية حق فرض العقوبة باسم المجتمع على الجاني. ونتيجة لذلك أصبحت الدية تعويضاً وترضية للمضرور أكثر من أنها عقوبة للجاني. وقد أنطبع بهذا التطور القانون الروماني

وكانت المسؤولية المدنية في هذه المرحلة لا تترتب إلا على الأفعال الضارة المنصوص عليها في القانون الروماني، دون النظر فيما إذا كانت تتضمن خطأ من جانب مرتكبها أم لا.

3. وفي مرحلة الثالثة: تأكد اعتبار الخطأ أساساً للمسؤولية، بحيث لا يعتبر الفعل الضار سبباً في مسؤولية مرتكبيه إلا إذا أمكن وصفه بأنه خطأ من جانب المسؤول.

ثم تطورت المسؤولية التقصيرية في ظل القانون الفرنسي القديم، الذي يرجع له الفضل في التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، ثم التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في إطار المسؤولية المدنية. وبالتالي ظهرت القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون الفرنسي القديم، وكرسها الفقيه الفرنسي دوما Domat، والمتمثلة بالقاعدة القائلة أن "كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلتزم مرتكبه بالتعويض". وكان جزاء هذه المسؤولية هو التعويض المدني الذي استقل عن فكرة العقوبة

4. وفي مرحلة رابعة: انتقلت المسؤولية التقصيرية بخصائصها هذه من القانون الفرنسي القديم إلى تقنين نابليون، التقنين المدني الفرنسي لعام 1914، أول تقنين معاصر في العالم. وبالإضافة إلى ذلك كرس هذا التقنين المسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الأشياء. وتم بذلك إدراج فكرة الخطأ المفترض لعدم كفاية الخطأ الواجب الإثبات لضمان حقوق الضحايا في التعويض

5. وفي المرحلة الأخيرة: تبين عدم كفاية الخطأ أصلاً كمعيار وضابط للمسؤولية المدنية خصوصاً بعد انتشار استعمال الآلات، وكثرة مخاطرها وتعذر تحديد مصدر الخطأ بين مالكيها وصانعيها ومستخدميها.

فظهر اتجاهان فقهيان:

✓ الاتجاه الأول: ويرى أصحابه أن من تسبب في الضرر بنشاط يجني ثماره فيجب أن يتحمل تبعته بغض النظر عن وجود الخطأ، بناء على قاعدة الغرم بالغنم، وأن أساس المسؤولية هو تحمل التبعة، فنادوا بالتحول من فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية إلى فكرة الخطر "Risque" بالانتقال من المسؤولية الشخصية إلى المسؤولية الموضوعية التي تتلاءم أكثر مع مجتمع يقوم على اقتصاد صناعي

✓ الاتجاه الثاني: وأصحابه يتشبثون بفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية ويعارضون الاتجاه الأول، ويرون أن فكرة تحمل التبعة تضع عوائق للإنتاج والنشاط الاقتصادي خوفاً من المسؤولية، وهذا يشل روح المبادرة ويضع عقبات في سبيل النمو والتقدم. و الحقيقة أن هذا الرأي التقليدي المحافظ لم يعد يتماشى تماماً مع الوضع الحالي للعام

تنظيم المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري

أورد القانون المدني الجزائري عددا من النصوص (124 الى 140) تتناسب مع أهمية المسؤولية التقصيرية. وقد عالج المشرع في هذه المواد العيوب التي كانت تشوب نصوص التقنين الفرنسي القديم كما استحدث فيها أحكاما جديدة، متبعا في هذا الخصوص نهج قضاة المحاكم الفرنسية من افتراض الخطأ في حالات معينة .

ومن هنا ظل المشرع الجزائري متمسكا بالأصل في تأسيس المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ . فجعله واجب الإثبات في مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية، وافترضه في المسؤولية عن فعل الغير، أو المسؤولية الناشئة عن الأشياء. أما نظرية تحمل التبعة فلم يأخذ بها القانون المدني الجزائري بشكل صريح بل سلك مسلك المشرع الفرنسي في ذلك. فأخذ بها في بعض التطبيقات الخاصة منها تعويضات حوادث العمل والأمراض المهنية والتعويض عن حوادث المرور. وفي حوادث الطيران والسفن البحرية....

الا اننا نؤكد على ان المشرع اخذ بنظرية تحمل التبعة ضمنيا في بعض حالات المسؤولية عن فعل الغير او الاشياء التي جعلها تقوم بقوة القانون دون اشتراط الخطأ ، فطبعا اصحاب النظرة التقليدية المحافظة للخطأ يفسرون موقف المشرع على انه اخذ بقرينة الخطأ المفترض غير القابل لاثبات العكس، الا ان الفكرة بذاتها تعد مجرد حيلة قانونية لا يتقبلها لا العقل ولا الواقع .

المحور الاول: شروط المسؤولية التقصيرية

المبحث الاول :

الفعل المولد للمسؤولية: من الخطأ الى الخطأ المفترض الى الخطر

الاصل في تصرفات الانسان انها تبني على الحرية. لكن هذه الحرية في التصرف تصطدم بحاجز منيع وهو عدم الاضرار بالغير، وبالتالي فإن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، قد ترجع هذه الاخيرة الى مبادئ الأخلاق، وقد يفرضها القانون وهذه الاخيرة التي تهمنا. اذ بمجرد تجاوزها ، فإن الشخص يتحمل تبعه ذلك، ويكون مسؤولاً عن تجاوز تصرفاته . فالمسؤولية اذن هي الجزاء الموقع على الشخص الذي ارتكب فعلاً يستوجب المؤاخذة

ومن ناحية اخرى فإن مفهوم المسؤولية التقصيرية قد مر بتطور هام ولا يزال، فبعد ان كانت هذه المسؤولية مقيدة بحالات معينة، اصبحت تتوسع تدريجياً الى ان اصبحت مبداء عاماً "الخطأ" (المطلب الاول). ومن ثم اخذ هذا المبدأ العام يتطور ايضاً، فبعد ان كان يقوم على فكرة الخطأ الواجب الإثبات (الفرع الاول)، ظهرت حالات كان الخطأ فيها مفترضا (الفرع الثاني)، بعد ذلك ظهرت حالات لا تقوم المسؤولية فيها على الخطأ ، واما على فكرة الخطر (المطلب الثاني) ، وهذه الحالات بدورها في تطور مستمر.

المطلب الاول : الخطأ التقصيري : المسؤولية الشخصية

استقر التقنين المدني على خطى تقنين نابليون المستنبط منه، على فكرة التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. وقامت المسؤولية المدنية كمبدأ عام على أساس الخطأ، وبذلك اعتبر الخطأ ركنا من أركان المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بوجوده

تعتمد النظرية الشخصية على فكرة الخطأ (Faute) كركن جوهري في المسؤولية التقصيرية. والخطأ يرتبط بسلوك الشخص المسؤول، لا يفرق بشأنه بين العمد وغير العمد

ولا يشترط في الخطأ لقيام المسؤولية أن يكون واجب الإثبات في جميع الحالات، بل يكفي أن يكون مفترض الوقوع في حالات المسؤولية عن فعل الغير أو الشيء.

من أهم مصادر المسؤولية التقصيرية وأولها التي نص عليها القانون المدني الجزائري : المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وقد نص عليها المشرع في المواد من 124 إلى 133 ، فوضع لها المبادئ والأحكام والآثار التي تتناسب مع هذه الفئة وربطها بعناصر لا يمكن بدونها إثارة مسؤولية المسؤولية عن الضرر، وهي فكرة الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

لم تضع التقنينات المدنية تعريفا للخطأ كركن للمسؤولية، تاركة ذلك للفقهاء، فعرفه PLANIOL على أنه "إخلال بالتزام سابق" ، وهذه الالتزامات هي الامتناع عن استعمال العنف، والامتناع عن استعمال الغش والخديعة، والامتناع عن القيام بعمل لم تتنبأ له القوة والمنهارة اللازمتين، واليقظة والحيطه في اداء واجب الرقابة على الأشخاص وعلى الأشياء.

فالخط هو انحراف في سلوك الشخص والتقصير ببذل العناية اللازمة بصورة تؤدي الى الاضرار بالغير، فتترتب المسؤولية التقصيرية بمجرد الاخلال ببذل العناية اللازمة بصورة تؤدي الى الإضرار بالغير، سواء اكان هذا عن عمد أي ينطوي عن قصد الاضرار بالغير او اعمال او قلة احتراز . والضابط او المعيار في ذلك هو السلوك المألوف عن الشخص العادي او رب الاسرة الصالح

الفرع الاول: الخطأ الواجب الاثبات

اولا: الخطأ الشخصي (م. 124 و م. 124 مكرر)

من أهم مصادر المسؤولية التقصيرية وأولها التي نص عليها القانون المدني الجزائري :المسؤولية عن الأفعال ال شخصية، وقد نص عليها المشرع في المواد من 124 إلى 125

تنص المادة 124 ق.م. " آل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"

تنص المادة 124 مكرر " يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية:-

- إذا وقع بقصد الاضرار بالغير، -

- إذا آن يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،

-إذا آن الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة"

تنص المادة 125 " لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا"

يستنتج من هذه النصوص ان ما يميز المسؤولية عن الفعل الشخصي هو كون الفاعل نفسه هو المسؤول الذي يلتزم بتعويض الضحية و ان الخطأ الواجب الاثبات هو اساس هذه المسؤولية

1- الخطأ المؤسس للمسؤولية عن الفعل الشخصي

سبق وان اشرنا الى اختلاف الفقهاء في تعريف الخطأ في ظل عدم تدخل المشرع لتحديد هذا الاخير، غير ان التعريف الفقهي المستقر للخطأ هو "الاخلال بالتزام قانوني عام". والمستقر عليه فقها وقضاء الآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدارته لهذا الإخلال. والذي يعني الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي المميز

بالتالي، يقوم الخطأ بهذا المفهوم على عنصرين، وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي، فالأول يتضمن التعدي أو الانحراف عن الالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير ، أما الثاني فهو العنصر المعنوي للإدراك أي ضرورة القصد أي إرادة الانحراف التي تنطوي بدورها على التمييز

- التعدي: الركن الموضوعي للخطأ

التعدي هو مخالفة القانون او التعسف في استعمال الحق بصوره الثلاثة المنصوص عليها في المادة 124 مكرر ق.م المذكورة اعلاه

والفرق بين مخالفة القانون والتعسف في استعمال الحق هو انه في الحالة الاولى يخرج الفاعل عن حدود حقه ، اما في الحالة الثانية فهو يسيئ استعمال حقه ، و في جميع الحالات يتمتع القاضي بالسلطة التقديرية لتقدير التعدي باعتباره الركن المادي للخطأ، حيث يقيس سلوك الفاعل بسلوك الرجل العادي المميز

ولا أهمية في مجال المسؤولية التقصيرية التمييز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، فكل منهما يوجب تعويض الضرر ولا فرق أيضا بين أن يتخذ انحراف الشخص مظهرا إيجابيا كإتلاف مال الغير أو مظهرا سلبيا كالامتناع عن إضاءة مصابيح السيارات أثناء السير ليلا. وسواء وقع الانحراف عمدا أو إهمالا. وقد اتفق رجال الفقه والقضاء أن المعيار الصحيح لقياس التعدي هو المعيار الموضوعي الذي يفترض في الناس جميعا أن يبلغوا درجة من اليقظة والفتنة كالرجل العادي الذي عرفه القانون برب الأسرة العادي.

فالمعيار الموضوعي ا يتغير من شخص إلى آخر ولا يتعلق بالأمور الخفية المتصلة بشخص المعتدي بل هو مقياس ثابت بالنسبة للجميع .

وإطار الإثبات يتعين على المضرور وهو المدعي ، طبقا للقاعدة العامة في الإثبات أن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ، وذلك بإثبات أن المدعى عليه انحرف عن سلوك الرجل العادي، بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن.

-الارادة: الركن المعنوي للخطأ

يعد عنصر الإدراك ركيزة المسؤولية عن الفعل الشخصي ، أي ضرورة القصد ، فيجب لقيام المسؤولية أن يكون المسؤول إراد التعدي بفعله ، ولما كان التمييز مناط الارادة فيشترط ان يكون المتعدي مدركا لأعمال التعدي الصادرة منه ، أي قادرا على التمييز بين الخير والشر، فلا مسؤولية لعدم التمييز، وعليه فإن القانون يشترط فيمن صدرت عنه هذه الأفعال ان يكون مكلفا أي مميزا يستطيع أن يعي ما في سلوكه من انحراف، وقد جاء في نص المادة 125 ق.م بانه يكون الشخص المسؤولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. وقد حدد سن التمييز ب 13 سنة شرط سلامة عقله من الجنون والعتة الذان يجعلان الراشد في حكم فاقد الاهلية

- درجات الخطأ:

- الخطأ العمدي : تكون فيه نية الاضرار
- الخطأ باهمال / عدم الاحتياط: يكون فيه ادراك لكن دون نية الاضرار
- الخطأ الجسيم: هو كالإهمال لكن عواقبه وخيمة، وتقد جسامته بالنظر الى خطورة ما يترتب عنه
- الخطأ غير المعذور: هو خطأ عمدي يندرج بين الخطأ الجسيم والغش

2- الافعال المبررة: مشروعية التعدي

هناك حالات محدودة لا يعتد فيها بالخطأ، وبالتالي لا يلزم فاعلها بالتعويض في حال اضراره بالغير وهي كالآتي:

- الدفاع الشرعي: تنص المادة 128 : "من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله، كان غير مسؤول، على أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي."
- يشترط في الدفاع الشرعي اربع شروط: ان يكون المدافع امام خطر حال على النفس او المال – ان يكون الاعتداء بغير وجه حق – ان يناسر الدفاع الاعتداء – الا توجد وسيلة اخرى لدفع الخطر
- طاعة اوامر الرئيس: تنص المادة 129: "لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصياً عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم"
- يشترط لمشروعية الاعتداء الصادر تنفيذا لأمر الرئيس: ان يصدر الفعل الضار من موظف او عون عمومي اذ لا يشمل الاستثناء العمال التابعين للقطاع الخاص – ان يحدث الضرر اثناء تنفيذ الأمر - ان يصدر الأمر من الجهة المختصة باصداره فيكون واجب الطاعة .
- حالة الضرورة: المادة 130 : "من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً اكبر، محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً."

يلاحظ انه خلافا للحكم المطبق في كل من حالة الدفاع الشرعي و طاعة اوامر الرئيس، لا يعفى من سبب ضررا للغير في حالة الضرورة من التعويض كليا ، لكن يكون التعويض عادلا يتناسب مع الحالة. وللقاضي السلطة التقديرية

- اذن القانون: تنص المادة 39 من قانون العقوبات " لا جريمة: 1- اذا كان الفعل قد امر او اذن به القانون". فاذا كانت المسؤولية الجنائية للشخص تستبعد كلما الحق ضررا بفعل امر او اذن به القانون ، فبالتبعية تستبعد مسروليته المدنية عن فعله الشخصي اذ لا يكون هذ الفعل خطأ تقصيري نظرا لمشروعيته

ثانيا: الخطأ المولد لمسؤولية حائز المال عن الاضرار الناشئة عن الحريق (المسؤولية عن الحريق)

تنص المادة 1-140 ق.م. " من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الاضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم "

اساس المسؤولية عن الحريق هو الخطأ الواجب الاثبات ، اذ يجب على المضرور اثبات ان الحريق ينسب الى خطأ الحائز او خطأ من هم تحت مسؤوليته (الخاضع للرقابة و التابع).

شروط قيام المسؤولية عن الحريق:

1. احتراق مال المسؤول: يجب ان يحترق مال المسؤول كلياً او جزئياً ، والحريق هو اشتعال النار في مال الحائز منقولا كان ام عقارا . ولا فلا مجال لتطبيق المادة 1-140 و تطبق المادة 124 بدلها (في حال عدم احتراق مال الحائز)
2. تسرب الحريق الى ممتلكات الغير ، فيحدث بها ضررا : بحيث يكون الحريق الذي شب في مال المسؤول هو السبب المباشر
3. خطأ المسؤول: فلا تتحقق مسؤولية الحائز إلا اذا ارتكب خطأ شخصي ادى الى نشوب الحريق سواء هو ام من هم تحت مسؤوليته ، ويقصد بهم الخاضع للرقابة والتابع، فيجب ان تثبت الضحية خطأ المسؤول او خطأ من هم تحت مسؤوليته
ولا يهم مصدر الحيازه مشروعة كانت ام غير مشروعة

ثالثاً: خطأ المنتج في المطابقة (مسؤولية المنتج)

خطأ اعدم المطابقة هو الخطأ الذي تقوم عليه مسؤولية المنتج

تنص المادة 140 ق.م. على ما يلي "يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية".

أدى التطور الصناعي و الاقتصادي إلى ظهور منتجات حديثة و متنوعة ساهمت في تحقيق المتعة و الرفاهية، الأمر الذي أدى إلى زيادة إقبال و تضاعف حاجات الإنسان عليها بمختلف أنواعها، غير أن هذه المنتجات أصبح يغلب عليها طابع التعقيد غالباً ما يصاحب بأضرار و مخاطر، هذا ما أدى بدوره إلى التعجيل بمسؤولية المنتج المدنية.

تعتبر المسؤولية التقصيرية للمنتج مجرد أثر يترتب على إخلاله لما التزم به قبل الغير قانوناً

1 - الخطأ في المطابقة هو اخلال المنتج بواجب السلامة المتوقعة

اثبات الخطأ في المطابقة هو اثبات العيب في المنتج لان العيب يكون



ناتجاً عنه

يعرف المنتج في الفقه القانوني على انه "كل ممتن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهداً واهتماماً خاصين فيكون له دور في تهيئتها أو صنعها و توضيها و من ثم خزنها في أثناء . صنعها و قبل أول تسويق لها". و عرف ايضاً بأنه "كل صانع للسلعة في شكلها النهائي أو أجزاء منها أو شارك في تركيبها أو أعد المنتجات الأولية لها"

يعرف المنتج في قانون المستهلك على انه "كل سلعة او خدمة قابلة للتنازل سواء بمقابل او بدون مقابل". يعرف كذلك بأنه "كل منقول مادي قابل للبيع و الشراء . تجارياً". ويعرف كذلك انه "كل منقول سواء تعلق الأمر بمادة أولية تم تحويلها . صناعياً أو لم يتم تحويلها و سواء تعلق الأمر بمنقول أندمج في منقول أو لم يندمج". ويعرف ايضاً على انه كل "شيء أو خدمة أو نشاط أو منظمة أو فكرة أو هو ثمرة الإنتاج"

لكن يقصد بالمنتج الذي تنطوي عليه مسؤولية المنتج التقصيرية طبقا للمادة 140 مكرر ق.م. على ".... كل ما هو منقول و لو كان متصلا بعقار و لاسيما المنتج الزراعي والمنتج الصناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري و البحري و الطاقة الكهربائية".

هذا ولم يعرف المشرع الجزائري المنتج في التقنين المدني الجزائري، غير أنه نص على الأشخاص الذين تنطبق عليهم مسؤولية المنتج، من خلال تحديد نطاق المنتج، اذ نجد أن مفهوم المنتج ينصرف إلى الصانع النهائي للمنتج . ومنتج المواد الأولية كالمزارعين و مشروعات الصيد و منتجي الطاقة الكهربائية

وعرف العيب في المنتج بأنه "الصفة الخطرة غير المألوفة بالمنتج"

و عرفت كذلك بأنه "العيب الذي يخل بالسلامة التي يعتمد عليها الجمهور . من المستهلكين عند تعامله مع المنتج فالصفة الغير الطبيعية أو الخطرة تعد عيبا "

كما عرف العيب بأنه " ذلك النقص في السلامة يهدد المستهلك بخطر في صحته أو أمواله أو جسده و يقصد بالخطر و الحال هذه حدث مستقبلي غير يقيني يترتب على وقوعه أثار .سلبية تتولد عن اختيار إنساني بين ممكنين أو أكثر"

و عرف بأنه " أي نقص أو خلل في المنتج أو في طريقة عرضه من شأنه أن يهدد سلامة المشتري أو الحائز بالخطر و يلحق به الضرر في .حيازته أو شخصه أو في أمواله "

من خلال التعاريف السالفة الذكر، يمكن أن نعرف المنتج المعيب على أنه " ذلك المنتج الذي يهدد المستهلك من الناحية المادية و المالية و هو بذلك يعني أنه لا يحتوي على عناصر السلامة التي يطمئن إليها المستهلك."

هذا وتنص المادة 1-11 من القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على انه " يجب أن يلبي كل منتج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته و صنفه و منشأه و مميزاته الأساسية و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة و هويته و كمياته و قابليته للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعماله "كما نصت المادة 2-11 من نفس القانون على ما انه " كما يجب أن يستجيب المنتج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه."

فالعيب اذن هو الاخلال بواجب السلامة المتوقعة، أي الاخلال بالتوقع المشروع للسلامة... ومصطلح المشروعية يفيد التأكيد على موضوعية المعيار

1- الخطأ في المطابقة اساس مسؤولية المنتج :

هناك من يجعل مسؤولية المنتج موضوعية لا تقوم على اساس خطأ المنتج الواجب الاثبات وانما على اساس عيب المنتج الذي يعتبرونه الفعل المولد للمسؤولية، وهو محدد بصفة موضوعية، فلا يحدوده بدرجة السلامة الواجب على المنتج بلوغها و انما بالتوقع المشروع للجماهور، وهو معيار موضوعي محض.

وهناك من يجعل مسؤولية المنتج قائمة على اساس الخطأ المفترض ، حيث ان وجود العيب قرينة على خطأ المنتج في المطابقة، او عدم بذله العناية الكافية لبلوغ درجة السلامة المفروض بلوغها الى بالحيطه اللازمة.

والحقيقة ان مسؤولية المنتج طبقا للمادة 140 مكرر ق.م. تقوم على اساس الخطأ الواجب الاثبات و هو الخطأ في المطابقة مع معايير السلامة، اذ ان المنتج اخل بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 9 الى 11 من قانون المستهلك، على غرار:

✓ الالتزام بأمن المنتجات والالتزام بالمطابقة

✓ الالتزام بنزاهة المنتج وقابليته للتسويق

✓ الالتزام بصمان سلامة الاشخاص من الاخطار الناتجة عن الاستعمال العادي للمنتج او الممكن توقعه

✓ الالتزام بمطابقة المنتج للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن

تعتبر المسؤولية التقصيرية للمنتج مجرد أثر يترتب على إخلاله لما التزم به قبل الغير قانونا

3- النظام القانوني لمسؤولية المنتج:

سشترط لقيام مسؤولية المنتج

- ان يكون الضرر ناتج عن عيب في المنتج : وعلى المضروران اثبت وجود عيب في المنتج وان هذا العيب هو الذي سبب له الضرر

- ان يكون المنتج هو المسؤول الوحيد: ويكون مسؤولاً حتى ولو لم تجمعه بالمتضرر علاقة تعاقدية ،
أي يكون مسؤولاً ولو كان المضروب من المنتج من الغير.

* ولا يمكن للمنتج دفع المسؤولية الا اذا اثبت السبب الاجنبي طبقاً للمادة 127 ق.م.

خلاصة : تعتبر المسؤولية التقصيرية للمنتج أثر يترتب على إخلاله لما التزم به قانوناً قبل الجمهور وهو
الالتزام مطابقة منتوجه مع معايير السلامة، وهي مسؤولية تقوم على اساس الخطأ الواجب الاثبات
حيث يشترط على الضحية اثبات وجود عيب في المنتج أي اثبات ان المنتج اخل بالتزام المطابقة.

الفرع الثاني : الخطأ المفترض

الخطأ المفترض ، مثله مثل الخطأ الواجب الاثبات هو اخلال بالتزام قانوني ، هو الانحراف على السلوك المعتاد للرجل العادي المميز ، فينتطوي بدوره على تعدي مع ادراك وتمييز. لكن خلافاً للخطأ الواجب الاثبات من طرف الضحية، ورغبة من المشرع في تخفيف عبء الاثبات على المضرور ينشئ لمصلحته قرائن قانونية تعفيه في بعض الاحوال من وجوب اثبات الخطأ، وذلك لما يكون الفعل الضار غير صادر عن الشخص المراد مساءلته مباشرة

تتجلى أهمية التمييز بين الخطأ المفترض و الخطأ الواجب الاثبات في دعاوي التعويض الناتجة عن المسؤولية التقصيرية في أن الخطأ المفترض هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، عن طريق نفي الخطأ من جانب المسؤول أو المدعى عليه ، أو عن طريق نفي العلاقة السببية بين الخطأ المفترض من جانبه و الفعل الضار ، بأن يثبت أن الضرر قد وقع نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الغير.

هذا وما يميز الخطأ المفترض ايضاً هو خلوه من عنصر إرادة التعدي ، كون المسؤول او الشخص المفترض فيه الخطأ لا يرد اساساً الفعل الضار ولم ينو الاضرار بالغير ، لذا فتكون الصورة الاساسية للخطأ المفترض هو الاهمال و هدم الاحتياط. ونجد في القانون المدني حالتين من الخطأ المفترض الذي يقيم المسؤولية التقصيرية: التقصير في الرقابة و اهمال الصيانة

اولاً: التقصير المفترض في الرقابة (مسؤولية متولي الرقابة)

تنص المادة 134 ق.م.: "كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار .

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية."

التقصير في الرقابة هو الخطأ المفترض في متولي الرقابة والذي تؤسس مسؤوليته لمجرد صدور فعل ضار عن الخاضع للرقابة ، فلا تلزم الضحية بإثبات خطأ متولي الرقابة لاقامة مسؤوليته بل تكفي بإثبات الفعل الضار الصادر عن الخاضع للرقابة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي اصابه لتنشأ

قرينة قانونية عن الخطأ في الرقابة ، وهي قرينة قانونية بسيطة يمكن لمتولي الرقابة نفيها، او نفي العلاقة السببية بين الخطأ المفترض في الرقابة وبين الضرر

مسؤولية متولي الرقابة هي مسؤولية شخصية عن فعل الغير، ونجد فيها شخصين محل اعتبار

1. متولي الرقابة : هو الشخص الذي له سلطة الرقابة على شخص اخر اما قانونا (مثل الاب او الوصي) او اتفاقا. على ان يكون المقصود بالرقابة هو الرقابة المادية وليس التوجيه والتربية تتضمن "التزام متولي الرقابة بمنع القاصر الذي تحت رقابته بالاضرار بالغير"

2. المشمول بالرقابة : هو الشخص الذي يخضع لرقابة وتوجيه شخص اخر (متولي الرقابة)، ويكون هذا الاخير قاصرا، اما بسبب سنه ، أي لا يتعدى 19 سنة طبقا للمادة 40 ق.م. ، او مصاب بمرض عقلي يفقده التمييز (الجنون أو العته)، او عاهة جسمانية تستدعي استعانتة بشخص يتولى الرقابة (العمى، الشلل...)

ويشترط لافتراض خطأ الرقابة (شروط مسؤولية متولي الرقابة): ان يصدر الفعل الضار من القاصر المشمول برقابة المسؤول المفترض: بطبيعته الحال نشترط الفعل الضار وليس الخطأ لانعدام عنصر الادراك عند عديم التمييز. ولا فرق ان يكون الفاعل قاصرا مميزا ام غير مميز ، اذ تظل قرينة الخطأ قائمة تعفي الضحية من اثباتها، إلا انه في حال كان الفاعل مميزا تجوز مساءلته مسؤولية شخصية على اساس المادة 124 ق.م. .. اذا تنص المادة 125 ق.م. انه "لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا" ، وفي هذه الحالة يلزم على الضحية بإثبات الخطأ الشخصي للقاصر

ثانياً :الاهمال المفترض للصيانة (المسؤولية عن تهمد البناء)

تنص المادة 140-2 ق.م. " مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه."

اهمال الصيانة هو الخطأ المفترض في مالك البناء والذي يؤسس مسؤوليته لمجرد تهمد بنائه، فمسؤولية المالك عن تهمد البناء هي مسؤولية عن فعل الشيء أساسها الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس

* الخطأ بإهمال هو التعدي الذي يرتكبه المرء دون قصد الاضرار بالغير، فيكون مدركا لما قام به من اهمال، غير انه لم ينو ولم يقصد من خلال هذا الانحراف في السلوك النتيجة التي ترتبت عنه في حق الغير، يحصل مثل هذا الانحراف بسبب عدم الاحتياط

ويشترط لافتراض خطأ اهمال الصيانة: (شروط المسؤولية عن تهمد البناء)

1. ان يكون تهمد البناء مصدر الضرر: والبناء هو مواد شيدھا الانسان سواء فوق الارض او بباطنها بحيث تصبح متصلة بالارض اتصال قرار (اي تصبح عقارا).

وتهمد البناء هو تفكك الاجزاء المكونه له عن بعضها البعض وانفصالها عن الارض . يتحقق الانهدام بانهيأ اجزائه سواء دلها او جزء منها . على ان يكون هذا التهمد لا ارادي، والا تقوم المسؤولية الشخصية على اساس المادة 124 ق.م ولا مجال لتطبيق المادة 140-2.

2. ملكية البناء: تجدر الاشارة الى ان اهمال الصيانة لا يفترض الا في مالك البناء دون غيره باعتباره المسؤول الوحيد بموجب المادة 140-2 ق.م وليس الجائز ، بغض النظر عما اذا كان هو من يشغل البناء ام لا

* ويسأل المالك من يوم انتقال الملكية اليه قانونا ، اي عند اتمام اجراءات الشهر العيني: وفي هذا الصدد يلاحظ ان المشرع افترض امران: خطأ المالك (اهمال الصيانة) وهي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس – وخطأ المالك الحالي للبناء بغض النظر عن الحالة التي انتقلت له فيها الملكية ، وهذه القرينة مطلقة غير قابلة لاثبات العكس

* هذا ويمكن للمالك كسر قرينة الخطأ ونفي المسؤولية اذا كسر رابطة السببية بين الخطأ المفترض في الصيانة والضرر، اي اذا اثبت ان الانهدام لا يرجع الى اهمال الصيانة او قدم المبنى . هذا الى امكانية نفي المسؤولية باثبات تدخل العنصر الاجنبي.

المطلب الثاني : الخطر (المسؤولية الموضوعية)

ان التطور الصناعي و الاقتصادي للاشياء والنشاطات التي اصبح غالبا ما تصاحبها أضرار و مخاطر، أدى بالمشرع إلى التعجيل بالمسؤولية التقصيرية لا على اساس الخطأ بل على اساس الخطر ، والمسؤولية على اساس الخطر او المخاطر هي مسؤولية موضوعية ، تنعدم فيها فكرة الخطأ بمعنى التعدي و الانحراف بالسلوك، اذ يتحمل الشخص بموجبها تبعة ما ينتجه بنشاطه او بالسلطات التي يخولها له القانون على اشياء محددة (حية كانت ام غير حية) ، من مخاطر على المجتمع

* نظرية تجمل التبعة:

ان نظرية تحمل التبعة نظرية تقييم المسؤولية التقصيرية على اساس عنصر الضرر، ولا تعند بالخطأ كركن من المسؤولية ، اذ ان مسؤولية الشخص تتحقق بمجرد توافر عنصر الضرر، وما على الشخص المتضرر الا ان يثبت الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، وهي احدى تطبيقات المسؤولية الموضوعية.

إن النقد الذي وجه إلى نظرية الخطأ، بل في توسع القضاء والفقه الفرنسيين في تجاوز الأصل في ترتيب المسؤولية والمتمثل بالخطأ الواجب الإثبات. والتوسع بالتالي توسعاً كبيراً في الأخذ بالخطأ المفترض، قد "حدا ببعض الفقه إلى أن يتساءل عما بقي من الأساس التقليدي للمسؤولية (الخطأ) إذ لا يكاد يشعر الإنسان بفرق بين مسؤولية لا تستند إلى خطأ أصلاً ومسؤولية تستند إلى خطأ مفروض، لا سيما إذا كان يمتنع على المسؤول إثبات عكسه، هذا زيادة على العلة الرئيسية، ألا وهي تعذر إقامة الدليل على خطأ المسؤول بعد ازدهار المنشآت الصناعية وتقدم وسائل النقل الحديث، ولذا فقد بدا ذلك بعضهم ومنذ أواخر القرن التاسع عشر في مهاجمة الخطأ كأساس للمسؤولية والدعوة إلى أساس جديد يوائم روح العصر الذي نعيش فيه وهو ما يسمى "الخطر المستحدث" أو تحمل "التبعة" ومؤدى هذا الأساس أنه ما دام الإنسان يستفيد من نشاطه الاقتصادي فعليه تبعة ما يحدثه لغيره من أضرار

بغير حاجة للبحث عما إذا كان هناك خطأ في جانبه أم لا... فحتى إذا لم يقع خطأ أصلاً من جانب المسؤول ليس من العدل التضحية بالمضرور وتحميله التبعة نتيجة ما وقع له، وقد خلصت للمسؤول مغانمه كلها.

وظهرت هذه النظرية أول الأمر بمناسبة إصابات العمل لتسهيل حصول العمال الذين يصابون في أثناء تأدية عملهم على تعويض مناسب.... بحيث تلخّصت في أن رب العمل يجب أن يعرض العمال عن إصابتهم بقطع النظر عن وقوع خطأ منه، لأن المصنع الذي أنشأه إنما يعود عليه ربحه ولأن إصابات العمل هي من المخاطر الملازمة لإنشاء المشروعات الصناعية وغيرها، فيجب أن يتحمل رب العمل نتائج هذه الإصابات لأن الغرم بالغنم ، ولأن هذه النظرية تؤسس المسؤولية على مجرد وقوع ضرر وعلى ضرورة إلقاء تبعة هذا الضرر على من تسبب فيه دون نظر إلى سلوك هذا الأخير أو إلى قصده، فقد سميت بنظرية المسؤولية الشيئية أو الموضوعية بالمقابلة للنظرية التقليدية التي تقيم المسؤولية على أساس سلوك الفاعل الشخصي، وهي المعروفة بنظرية المسؤولية الشخصية .

ولكن رغم هذه الحجج وغيرها، فلا يزال بعض الفقه يرى المسؤولية مسؤولية شخصية، قوامها الخطأ الشخصي ثابتاً كان أو مفروضاً، ويرفض التسليم بهذه المسؤولية المادية لمخالفتها لروح التشريع الذي يبدو من نصوصه تطلب الخطأ الشخصي، كما أن الفكرة التي تقوم عليها فكرة غامضة ينقصها التحديد، فوق ما تؤدي إليه من زيادة قضايا المسؤولية زيادة قد يخشى منها على النظام الاجتماعي ذاته، ولأن من شأن الأخذ بها قتل العزيمة وروح الإقدام

تقوم نظرية تحمل التبعة على أساس الضرر، ولا تقيم وزناً للخطأ وقد انقسم أنصار هذه النظرية إلى فريقين:

فأما الفريق الأول: يقيمها على أساس "قاعدة الغرم بالغنم" : بحيث أن المسؤول يسأل عن الفعل الضار ولو لم يصدر منه (فعل الغير أو الشيء) في مقابل المنفعة التي يجنيها من نشاطه، فعلى الشخص الذي يستعمل في نشاطاته أشياء أو أشخاصاً قصد الانتفاع بهم أو بخدماتهم، أن يتحمل مقابل ذلك عبء الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأشياء أو الأشخاص للغير.

فوفقاً لقاعدة الغرم بالغنم تجد المسؤولية القائمة على تحمل التبعة أساسها في فكرة "المنفعة" التي هي فكرة اقتصادية مفادها أنه من يستفيد من مصادر معينة عليه أن يتحمل مغارمها عندما تسبب أضراراً للغير

لكن ما يلاحظ هو ان هذه القاعدة تعجز عن تفسير الحالات المختلفة للمسؤولية الموضوعية، اذ انها تتعلق فقط بالانشطة المربحة او على الاقل تلك التي تنطوي على امل الربح ولو كان ضئيلا

أما الفريق الثاني: فيرجع أساس النظرية إلى "الخطر المستحدث": ملخص هذه القاعدة هو ان كل من يستحدث بنشاطه خطرا متزايدا للغير فإن عليه تحمل تبعه هذا الخطر. وهذه القاعدة اوسع من قاعدة الغرم بالغرم . اذ انه طالما ترتب على نشاط الشخص ضرر على الغير كان مسؤولا عن تعويضه بغض النظر ان كان نشاطه هذا اقتصاديا ام لا

بمعنى أن المسؤول عند استخدامه للشيء او لخدمات الغير في نشاط ما فإنه يستحدث أخطارا ومن ثم يتوجب عليه تحمل النتائج المترتبة على هذه الأخطار.

* نظرية الضمان.

ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم " ستارك Starck " إلى إقامة المسؤولية المدنية بوجه عام على أساس الضمان لا على أساس الخطأ وترى هذه النظرية أنه متى ثبت أن المضرور قد أؤذي في حق من حقوقه دون مسوغ من القانون كان المتسبب في هذا الضرر مسؤولا عنه بغض النظر عن سلوكه، وبالتالي فهو موجب للضمان بذاته ما دام القانون لم يلزم المضرور بتحمل هذا المساس بحقه، وذلك لأن غاية المسؤولية المدنية هي التعويض المدني عند المساس بحق الضمان المعزز للغير، أما إذا ثبت ارتكاب الفاعل خطأ، فإنه يترتب على هذا الخطأ زيادة مبلغ التعويض على أساس عقوبة خاصة وقد ظهرت هذه الفكرة في القوانين التي ارتكزت على الالتزام بالضمان التي نظمت إصابات العمال والأخطاء المهنية على أساس ضمان سلامة العامل والأحكام القضائية المتعلقة بمسؤولية أمن نقل الركاب.

ومن جهتنا لا نرى في هذه النظرية اساسا مستقلا للمسؤولية التقصيرية كونها لا تعبر إلا عن صورة من صور تحمل التبعة نظرا لأنها لا تقيم المسؤولية على أية شروط بل يكفي فيها حدوث ضرر .

ورد في القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية خطرين يقيمان المسؤولية عن فعل الغير وفعل الاشياء

✓ الاخطار المستحدثة بنشاط المتبوع والتي تقيم مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه على اساس المادة 136 ق.م.

✓ الاخطار المستحدثة باستخدام الشيء والتي تقيم المسؤولية عن فعل الاشياء وفعل الحيوانات على اساس المادة 138 ق.م و 139

اولا: الاخطار المستحدثة بنشاط التابع لحساب المتبوع (مسؤولية المتبوع عن افعال التابع)

تنص المادة 136 ق.م. " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها .

وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع"

تعالج المادة 136 مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه، وهي مسؤوليه موضوعية عن فعل الغير اساسها تحمل المسؤول تبعة الاخطار المستحدثة بنشاط تابعه

ويشترط لتحمل المتبوع تبعة مخاطر تابعه (شروط مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه):

1. وجود علاقة تبعية : سابقا كانت تقوم على اساس حرية المتبوع في اختيار تابعه + سلطة الرقابة والتوجيه التي يتمتع بها (سلطة توجيه الاوامر) ، بكن تم هجر المعيار لعدم تماشيه مع الواقع الحالي لعالم الشغل

حاليا: تحدد حلقه التبعية بمجرد عمل التابع لحساب المتبوع سواء كانت سلطة توجيهه او رقابة ام لا

2. صدور فعل ضار من التابع: اشترط المشرع الفعل الضار ولم يشترط الخطأ ، ذلك ان الغرض من اقامة مسؤولية المتبوع هو اعفاء الضحية من اثبات الخطأ

* هناك فرضيتان حول الاساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه:

❌ نظرية الضمان: اذ ان المتبوع يضمن مسؤولية التابع، والغرض من ذلك هو حماية الضحية من حالة اعسار التابع

هذا الاساس غير صائب لان مسؤولية المتبوع ليست مؤقتة، ولا يمكن لهذا الاخير الرجوع على التابع الا في حالى الخطأ الجسيم ، وهذا ما قضت به المادة 137 ق.م. " للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما"

✅ تحمل تبعة الاخطار المستحدثة بنشاط التابع لحساب المتبوع: وهذا طبقا لقاعدة الغنم بالغرم ، اذ ان المتبوع يستفيد من نشاط تابعه أي له مغنم من استخدامه لهذا التابع . وفي المقابل فإنه

يستحدث خطراً على المجتمع بنشاط تابعه هذا، وعليه تحمل تبعه هذا الاخطار من افعال ضارة على الغير

وكنتيجة لهذا فلا يكون للمتبع دفع المسؤولية حتى ولو اخطأ التابع ، وحتى ولو خرج هذا الاخير عن حدود مهامه

لماذا تعتبر المسؤولية المتبوع عن افعال تابعه موضوعية؟

- ✓ يمكن اصلاً مساءلة التابع عن فعله الشخصي.
- ✓ لا يمكن للمتبع دفع المسؤولية عكس متولي الرقابة ، ولا عبء في ذلك بخطأ التابع
- ✓ الملزم بالتعويض في نهاية المطاف هو شركة التأمين كون قانون التأمين يلتزم كل محترف لنشاط اقتصادي بالتأمين

خلاصة : مسؤولية المتبوع عن فعال تابعه مسؤولية شخصية ولدست مسؤولية عن فعل الغير ، اساسها ليس الخطأ و انما اساسها موضوعي وهو الخطر.

ثانياً: الاخطار المستحدثة باستخدام الشيء (المسؤولية عن فعل الاشياء والحيوانات)

المادة 138 : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير ، والرقابة ، يعتر مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

ويعفي من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية ، أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو القوة القاهرة.

المادة 139 : "حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر . ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه."

تعالج المادتين 138 و 139 مسؤولية حارس الشيء مسؤولية حارس الحيوان ، و كليهما مسؤولية موضوعية عن فعل الاشياء (الحية وغير الحية) اساسها تحمل المسؤول تبعه الاخطار المستحدثة باستخدامه للشيء الذي تحت حراسته.

ويشترط لتحمل الشخص تبعه مخاطر الاشياء التي يحرسها (شروط مسؤولية حارس الشيء):

1- ان يكون الضرر من فعل الشيء:

ترمي المادة 138 الى كل شئ مادي غير حي بغض النظر عن صنفه او نوعه عقار، منقول ، صلب، سائل، غازي وهناك جدل فقهي حول الاموال غير المادية مثل البرامج المعلوماتية ، التي لا تعتبر اشياء بمفهوم المادة 138 لا سيما وأنها غير قادرة على احداث الضرر بصورة مستقلة عن يد الانسان ، وهذا ما يجعلها مجرد وسيلة لإحداث الفعل الضار بحيث تنعدم الحاجة الى المادة 138 اذ تكون المسؤولية هنا على اساس الفعل الشخصي بموجب المادة 124 ق.م.

ويستثني من مفهوم الشيء بمعنى المادة 138 ق.م.: المنتجات متى كانت معيبة (140 مكرر) ، البناء متى تهدم و المال المحترق (140)، المركبات متى سببت اضرارا جسمية للغير (امر 15-74) اذ تخضع كل منهم الى المواد الخاصة التي تنظمه كما رأينا سابقا. هذا، هذا الى جانب الحيوان الوارد حكمه في المادة 139 التي ترمي من جهتها الى كل كائن حي من غير الجنس البشري

كما يستثني من مفهوم الشيء بمعنى المادة 138 ق.م. الأشياء التي تخرج عن مفهوم الأشياء بنص المادة 138 ق م ج بحكم طبيعتها هي: جسم الإنسان حيث لا يعتبر هذا الأخير شيئاً ما دام صاحبه حياً ولا يكون أمام المضرور إلا المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جسم الإنسان وفقاً لنص المادة 124 ق م ، ولو كان في حالة إغماء أو نوم ، وكذلك الأشياء السائبة وهي الأشياء التي تخلق عنها حارسها أو لم تكن مملوكة لأحد مثال : المطر، الثلوج ، أولم يكن الشيء في حيازة إنسان وقت الحادث.

وذلك نظراً لأن المسؤولية عن الأشياء تقوم على أساس فكرة الحراسة وليس الشيء في حد ذاته

هذا، ويشترط ان يكون الضرر من فعل الشيء، أي ان يكون للشيء دور فعال في احداث الضرر، ومعيار الفعالية هو ان يكون الشيء في وضع غير طبيعي سواء كان متحركاً ام ساكناً

2- ان يكون الشيء مصدر الضرر تحت حراسة المسؤول:

يقصد بالحراسة حسب نص المادة 138 ق م " السلطة الفعلية على الشيء بالاستعمال والتسيير والرقابة.

وعليه فان الحراسة تقتضي السلطات الثلاث: الاستعمال، والتسيير، والرقابة.

* سلطة الاستعمال: هي استخدام الشيء باعتباره أداة لتحقيق الغرض أو الغاية التي أعد من أجلها، كاستعمال سيارة باعتبارها وسيلة نقل.

وليس بالازم وجود الشيء ماديا لدى الحارس أو واضعا يده عليه ، بل يكفي أن تكون له سلطة استعماله وإن لم يمارسها ماديا ، فلا تقتضي سلطة الاستعمال أن يكون الشيء بيد الحارس فالمتبوع الذي يكلف تابعه باستعمال اله قطع الخشب يعد مستعملا للالة كونه هو الذي يصدر الأوامر بشأن الاستعمال .

* سلطة التسيير: ومفهومها له معنيان:

* المعنى المادي: الذي يعني أن يكون الشيء بين يدي شخص يتولى استعماله كالعامل الذي يستعمل آلة المتبوع له سلطة التسيير بالمعنى المادي،

* أما التسيير في معناه المعنوي يقصد به سلطة إصدار الأوامر والتعليمات بشأن استعمال الشيء فصاحب العمل هو الذي يتولى تحديد الطريقة الواجب إتباعها لاستعمال الآلة وأيام و ساعات العمل في حين يكتفي العامل بالتسيير المادي للآلة طبقا للأوامر السالفة الذكر

والمقصود بالتسيير في نص م 138 من ق، م، ج هو سلطة التسيير المعنوي و عادة من كان له سلطة استعمال الشيء تكون له في نفس الوقت سلطة تسييره .

* سلطة الرقابة: تتحقق متى كانت للحارس سلطة فحص الشيء وتعهده بالصيانة اللازمة حتى يؤدي الغرض الذي خصص له كما يدخل في مفهوم الرقابة أيضا سلطة الملاحظة وتتبع الشيء في استعماله وتفحصه وتأمين صيانتته وإصلاح العيب الذي يظهر فيه ومحاسبة، وتتبع استعمال الشيء من طرف الغير .

- اما عن حراسة الحيوان: فهي السيطرة الفعلية عليه في التوجيه و الرقابة، سواء كانت هذه السيطرة الفعلية تستند إلى حق أو بدون حق.

* وهناك قرينة على أن مالك الحيوان هو الحارس كونه في الأصل صاحب السيطرة الفعلية عليه. فإذا رجع المضرور على المالك فلا يكلف بإثبات أنه الحارس، بل المالك هو من يقع عليه عبء الإثبات أنه لم يكن الشيء تحت حراسته وقت حدوث الضرر، كما هو الحال لمستأجر حصان يركبه على أن يتولى قيادته فيكون مسؤولا عما يحدثه من ضرر كحارس ولا يسأل عنه المالك.

هذا ، وفي حال انتقال حراسة الشيء من شخص لآخر:

✓ اذا انتقلت بإرادة الحارس كأن يبيع الشيء محل الحراسة أو يؤجره أو يعيره شخصا آخر ، لابد أن نرجع في كل مرة إلى مضمون التصرف القانوني و البحث ما إذ كان الحارس قد تخلى عن سلطات الاستعمال و الرقابة و التسيير لفائدة الشخص الثاني أم لا ، فبائع المنقول مثلا يبقى حارسا للشيء ما لم يتسلمه المشتري رغم اكتسابه ملكية الشيء.

- كما قد تنتقل الحراسة استثناء إلى التابع برضاء متبوعه، كأن يجيز المتبوع (المالك) للتابع أن يستعمل الشيء في غرض خاص و شخصي لا يرتبط بالخدمة .

✓ اما اذا انتقلت الحراسة بغير إرادة الحارس كما في حالة سرقة الشيء، فالسارق الذي يحوز الشيء و يمارس عليه سلطة الاستعمال و التسيير و الرقابة يكون مسؤولا عن الضرر الذي يتسبب فيه الشيء المسروق باعتباره حارسا له .

* و قد تكون الحراسة جماعية بحيث يكون لأكثر من شخص في نفس الوقت سلطات الاستعمال و التسيير و الرقابة، كأن يقوم شخصان يملكان آلة لقطع الخشب، باستثمارها معا فيشتركان في استعمالها و تسييرها و رقابتها، فإنهما يكونان مشتركين في حراسة هذه الآلة، و يكونان بذلك مسؤولين بالتضامن اتجاه الضحية عن الأضرار التي تسببت فيها هاته الآلة .

أساس المسؤولية عن الأشياء وفقا للمادتين 138 و 139 ق.م.

لم يقف الفقه القانوني على تحديد الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري في تحديد اساس المسؤولية عن الاشياء الحية و غير الحية بموجب المادتين 138 و 139 ق.م. : إما الخطأ في الحراسة كأساس لهاته المسؤولية. وإما أن هذه المسؤولية هي مسؤولية موضوعية بقوة القانون في جانب الحارس ، اساسها تحمل تبعة مخاطر الشيء و هذا هو الرأي الصائب.

❌ 1- الخطأ في الحراسة لا يصلح كأساس للمسؤولية عن الأشياء / الحيوانات.

يرى بعض الفقهاء أن أساس المسؤولية عن حراسة الأشياء حية كانت ام غير حية هو الخطأ في الحراسة، المفترض في جانب الحارس و هو خطأ لا يقبل إثبات العكس، فلا يجوز لحارس الشيء إثبات أنه لم يخطأ أو أنه بذل العناية المطلوبة لمنع وقوع الضرر (كما هو الحال بالنسبة لمتولي الرقابة و مالك المبنية المنهار)، فإذا وقع ضرر للغير بفعل الشيء او الحيوان فيفترض أن الحارس قد فقد السيطرة

الفعلية على الشيء او الحيوان وأن زمامه قد أفلت منه وهذا الإفلات هو عين الخطأ، وقد ثبت هذا الإفلات بوقوع ضرر ولا حاجة لإثباته بدليل آخر ولا جدوى من إثبات عكسه .

ولا يستطيع الحارس دفع هاته المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب هو القاهرة أو الحالة الطارئة أو فعل الضحية أو فعل الغير، والمضروب لا يكلف بإثبات الخطأ لأنه مفترض في جانب حارس الشيء بل يكفيه إثبات أن الضرر حدث له من جراء فعل الشيء.

كما يرى هذا الجانب من الفقه أن أساس المسؤولية عن الأشياء هو الخطأ المفترض في جانب الحارس لأن هناك التزاما محددا يقع على حارس الشيء او الحيوان وهو منعه من إحداث الضرر .

لكن في الواقع تعد فكرة الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس والذي ينطوي على مجرد حدوده الضرر غير منطقية تماما ولا تتماشى مع جوهر الخطأ مسؤولية حارس الشيء مسؤولية بقوة القانون.. ذلك أن المشرع الجزائي افترض مسؤولية حارس الشيء لمجرد أن يترتب عن فعل الشيء محل الحراسة ضرر للغير فالمضروب لا يلزم بإثبات خطأ الحارس بل يكفيه إثبات أنه لحقه ضرر وأن ذلك الضرر هو من فعل الشيء وأن هذا الشيء هو محل الحراسة من قبل الحارس المسئول .

فيفرض القانون مسؤولية الحارس لمجرد أن يسبب الشيء ضررا للغير بغض النظر عن سلوك الحارس ، ولا يهم إن كان مخطئا ام لا، وجعل هذه المسؤولية مقررة حكما إذا ارتبط الشيء بالضرر ارتباط سببيا ، ولا يعفى الحارس من مسؤوليته بإثبات أنه لم يخطأ، أو أنه قام بواجب العناية في حراسة الشيء لمنع وقوع الضرر بل يكلف بإثبات السبب الأجنبي حسب ما نصت عليه المادة 138 ق م بأن الضرر الذي حدث كان بسبب لا ينسب إليه ، (القوة القاهرة ، أو الحادث المفاجئ ، أو عمل الضحية ، أو عمل الغير)

✓ 2 - الخطر أساس مسؤولية حارس الشيء والحيوان (نظرية تحمل التبعة)

راينا كيف ان القانون يفرض مسؤولية الحارس بغض النظر عن سلوكه إن كان مخطئا ام لا، اذ جعل هذه المسؤولية مقررة حكما إذا ارتبط الشيء بالضرر ارتباط سببيا ، ولا يعفى الحارس من مسؤوليته بإثبات أنه لم يخطأ . اذ تقوم مسؤولية الحارس على أساس نظرية المخاطر ، أو تحمل التبعة، فالحارس ، قد يأتي وهو يستخدم الشيء او الحيوان في نشاطه في حدود حقه، وضمن نطاق مشروع، دون أن يصدر خطأ منه ، أو تعسف، ويترتب على هذا الاستخدام اضرارا تلحق بالغير او

استحداث اخطار على الغير فيتحمل تبعة تلك الاخطار، وذلك على أساس فكرة الغرم بالغنم .
فالحارس يستفيد من الشيء الذي يجر عليه نفعاً، فإن عليه في المقابل أن يتحمل مغارمه، فليس من
العدل أن ينتفع الحارس من سلطاته ، ويستأثر بمنافعها، ويترك لغيره أن يتحمل مخاطرها، فأولى به
هو أن يتحمل تلك المخاطر، فمن له النفع، حقت عليه التبعة .

كيفية دفع المسؤولية عن الأشياء .

طالما نحن امام مسؤولية موضوعية بقوة القانون فإن السبب الأجنبي هو وحده الذي يعفي الحارس
من المسؤولية. حيث ينفي رابطة السببية بين الضرر وتدخل الشيء ومن وسائل دفع مسؤولية حارس
الشيء والتي يلجأ إليها هي السبب الأجنبي أو اثبات التدخل السلبي للشيء في إحداث الضرر. (و. 138 –
2 و 139 ق.م.).

ويقع عبء إثبات السبب الأجنبي أو الدور السلبي لتدخل الشيء على حارس الشيء حتى ينفي عنه
المسؤولية.

المبحث الثاني : الضرر

وهو ركن جوهري من أركان المسؤولية المدنية بنوعها العقدية والتقصيرية، بل هو مناط هذه المسؤولية التي لا تقوم في حال انتفائه.

الفقرة الأولى: تعريف الضرر:

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، وبمعنى آخر هو إخلال بمصلحة مشروعة، سواء كانت هذه المصلحة مادية أو دني. فالضرر هو كل ما ينجم عن الاعتداء على حق من حقوق الشخص، أو عن الإخلال بمصلحة مشروعة له.

وحتى يكون هناك إضرار بمصلحة مشروعة يجب أن يثبت الضرر بأنه فقد شيئاً بسبب الفعل الذي ينسبه للفاعل. وفي مثل هذه الحال يتم المقارنة بين الوضع الحالي للضرر والوضع الذي كان من الممكن أن يكون موجوداً لو لم يقع الفعل الضار. ولا تتم المقارنة مع الوضع السابق لوقوع الفعل من أجل التأكد من وقوع الضرر، مثال لو أن زوجة المتوفى، بنتيجة حادث سير، حصلت على عمل بعد الحادث، وبالتالي فإن هذا العمل منحها وضعاً مالياً مشابهاً أو أفضل من الوضع الذي كان يؤمنه لها زوجها قبل وفاته، فإن ذلك لا يحرمها من حقها في المطالبة بالتعويض بسبب فقدان المساهمة التي يقدمها لها زوجها قبل وفاته.

ولكن يجب في كل الأحوال أن يترتب على الفعل المنسوب للمسؤول خسارة بالنسبة للضرر. ففي بعض الأحيان، على الرغم من أن الفعل المولد للمسؤولية يكون سبباً لظهور دين على شخص ثالث، فإن هذا الدين لا يشكل دائماً ضرراً، وذلك لأنه يمكن أن يرافقه فائدة له، فاستناداً إلى ذلك فإن النفقة المترتبة على الوارث، نتيجة وفاة موروثه بسبب حادث، والمتمثلة بتسديد ضريبة التركات لا تشكل ضرراً ناجماً عن الحادث الذي أدى إلى وفاته موروثه، وبالتالي لا يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

وتختلف أهمية الضرر كركن من أركان المسؤولية المدنية تبعاً لألساس القانوني لهذه المسؤولية. فإذا كانت المسؤولية تقوم على الخطأ، فإن الضرر له مكانة ثانوية في هذه المسؤولية لأنه لا من معطياتها الجوهرية. أما إذا كانت المسؤولية تقوم على تحمل التبعة، فإن الضرر فيها يحتل مكانة

بارزة. ولا يشترط لقيام الضرر أن يقع اعتداء على حق مالي للمضرور، وإنما يمكن أن يقع على حق غير مالي أيضاً. ويترتب على ذلك أن الضرر، كركن من أركان المسؤولية، يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً.

الفقرة الثانية : أنواع الضرر

الضرر نوعين:

1- **الضرر المادي:** وهو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو بمصلحة سواء كان الحق حقاً مالياً أو غير مالي. ويتمثل في الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية أو الفكرية أو الصناعية.

كما قد يترتب الضرر المادي عن المساس بسلامة جسم الإنسان، ويترتب عن ذلك خسارة مالية إذا كان ضرراً مادياً مثل العجز عن الكسب أو نفقات العلاج.

فالعبارة في الضرر المادي بما يلحق المرء من خسارة مالية وما يفوته من كسب جراء المساس بحق في جسمه أو ماله.



الضرر المادي = انتقاص من الذمة المالية

2- **الضرر المعنوي:** وهو الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته. وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبرها ضرراً أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من إبداء للسمعة. أو عن آلام النفس وحرمة عائلته وشرفها.

وقد أجمع الفقه والقضاء على أن الضرر الأدبي يستوجب التعويض كالضرر المادي. غير أن القانون المدني الجزائري لم ينص بصراحة العبارة عن التعويض الأدبي، وإنما صياغة المادة 124 ق.م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي.

3- **الضرر البيئي:** هو كل ما يلحق البيئة من تلوث فيصيب صحة الإنسان أو ممتلكاته

والبيئة هي الطبيعة الحية وغير الحية : الهواء- الماء - الجو - الأرض - باطن الأرض - الحيوانات - النباتات

والضرر البيئي هو التلوث او التغيير الذي يطرأ بالبيئة فيلحق ضرر في صحة الانسان او بالطبيعة. وهذا الشرط اساس للتعويض . فاذا اصاب الضرر البيئي الطبيعة في حد ذاتها أي في عناصرها غير المملوكة لا تتحقق المسؤولية لانتفاء الطابع الشخصي من الضرر

* **الضرر المرتد:** وهو الضرر المنعكس، لأنه يقع بطريق الارتداء لضرر آخر ويكون نتيجة له، ويعتبر ضررا مباشرا بتعيين التعويض عنه ومن أمثلة ذلك الضرر الذي يلحق الأسرة نتيجة موت عائلتهم في حادث . والضرر الذي يلحق الزوجة نتيجة افلاس زوجها.

الفقرة الثالثة: شروط الضرر الموجب للتعويض

ينبغي أن يستجمع الضرر مجموعة من الشروط حتى يكون مستحقا للتعويض، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون شخصيا، محققا، مباشرا، وأن يمس بحق ثابت أو مصلحة مالية مشروعة .

اولا: أن يكون الضرر شخصيا : اي أن يصيب المدعي شخصيا (او من ينوب عنهم قانونا)، فتتوفر فيه المصلحة الشخصية حتى تكون دعواه مقبولة.

ويتحقق هذا الشرط حتى بالنسبة للاضرار المتردة عن الضرر الاصلي، إذ يعتبر الضرر المرتد ضررا شخصيا لمن ارتد عليه. كما لو أصيب شخص في حادث بما أعجزه عن القيام بعمله، وبالتالي يحول دون الانفاق على من يعولهم، فلهؤلاء الحق في طلب التعويض عما لحق بكل واحد منهم من ضرر شخصي، وهذا التعويض مستقل تماما عما يطالب به الشخص العائل من إصلاح مما أصيب هو به من ضرر. فيكون للضرر المرتد كيان مستقل عن الضرر الاصلي، ويترتب على هذا أنه يمكن لمن أصابه ضرر مرتد المطالبة بالتعويض عنه، حتى لو اتخذت الضحية موقفا سلبيا من حقها في التعويض عن الضرر الذي أصابها أو تنازلت عنه. وإذا توفيت الضحية المعيلة لأشخاص آخرين دون أن تكون قد طالبت بحقها في التعويض فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثتها من بعدها، فيجتمع لديهم هذا الحق مع ما لحق بهم من ضرر مرتد بسبب حادث معيّلهم، اما إذا كانت الضحية قد تنازلت عنه حال حياتها فيبقى لهم الحق في التعويض عن الضرر المرتد الذي لحق بهم، وما يقضي به من تعويض لا يعتبر تركه، فلا يقسم بين الورثة.

ثانيا: أن يكون الضرر محقق الوقوع :

والمقصود بهذا ألا يكون الضرر افتراضي او محمّل الوقوع، بل يجب أن يكون قد وقع فعلا أو أن يكون وقوعه مؤكدًا وحتميًا ولو تراخى إلى المستقبل.

فالضرر الحال هو الضرر الذي وقع فعلا، وتكونت عناصره و مظاهره التي توفر للقاضي معطيات تقويمه، ومثاله ما أصاب المضرور في جسمه أو ماله وقت المطالبة بالتعويض كذلك إذا ما أدى حادث تصادم إلى عطل مادي بالسيارة، وإلى تعطيلها عن السير لفترة محددة، فالضرر يكون حالا بتبيان العطل الذي أصلح والتعطيل الذي حصل فيعود للقاضي أن يحدد تكاليف تصليح العطل، بدل التعطيل المتمثلا بخسارة ما كان يجنيه صاحب السيارة من استعمالها، لو كان هو الذي يستثمرها، أو بتكاليف تنقلاته لو اضطر إلى استئجار سيارات لغرض تنقل.

والضرر قد يكون نهائيا منذ وقوع الحادث، أو يصبح كذلك وقت الحكم بالتعويض بعد أن استقر، فيكون تقويم الضرر على أساس ما كان عند الحادث في الحالة الاولى، وعلى أساس ما استقر عليه في الحالة الثانية. وإذا لم تستقر حالة الضرر، واستمر مختلفا بين الخطورة والتحسين، فللقاضي الحكم بتعويض يناسب ما قدره من ضرر واقع فعلا، وأن يحفظ الحق للمضرور باستكمال التعويض حسبما تنتهي إليه حالة الضرر، مادام أنه محقق وليس احتمالي، وهذا في مدة معينة. طبقا لنص المادة 131 من التقنين المدني الجزائري "يقدر القاضي مدى التعويض الذي لحق المصاب طبقا لاحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير."

والضرر المستقبل هو الضرر الذي تحقق سببه، ولكن لم تكتمل مقوماته في الحاضر، وإن ظهر ما يجعل حصوله في المستقبل أكيدا. وهو يأخذ في الغالب شكلين:

1- فإما أن يكون من توابع الضرر الاصلي الحال، يتفرع عنه في تطوره، ولكن يتراخى زمنيا بعده حتى يتحقق وجوده. ومثاله أن يصاب شخص بعطل دائم يعجزه عن العمل، فعطله الدائم الذي ثبت نهائيا هو الضرر الحال، ولكن إذا كان هذا العطل سيؤدي حتما إلى حرمان المصاب من دخل كان يجنيه، فهذا يعد من الاضرار المستقبلية. وإذا كانت هناك إصابة في عضو نتج عنها مضاعفات، تنبئ أن هناك عجزا سيحصل به، فالقاضي ان يحدد التعويض عن نفقات المعالجة ، حتى يوم حكمه، أما العجز في العضو وما يخلفه من آثار في المصاب، فتقويمها يعد من الاضرار المستقبلية

2- وقد ينشأ الضرر المستقبل بعد فترة من الإصابة، بفعل مضاعفات من غير أن يكون عند حصولها منبئة بالضرر المستقبل، فيكون هذا الضرر المستقبل غير متوقعا وقت الحكم بالتعويض، فلا يدخله القاضي في حسابه عند تقديره. ومثاله: أن تؤدي إصابة الضحية إلى مضاعفات خطيرة، دون أن يكون متوقعا وقت تقدير التعويض أن هذه الإصابة قد تتفاقم. إذ أن المبدأ أن الحكم بالتعويض يشمل كل ما ترتب من ضرر وقع فعلا، أو سيتحقق وقوعه مستقبلا متى كان متوقعا، وأن عناصر التعويض المحددة للاضرار الحالية وما يترتب عنها مستقبلا، والتي اشتمل عليها الحكم، تحوز قوة الشيء المقضي به وبالتالي لا يجوز للمضرور أن يعيد المطالبة بالتعويض، عما لم يكن محققا وقت صدور الحكم.

وتأخذ هذه الحالة صورتين

- ✓ إما أن يتفاقم الضرر الأصلي بعد الحكم بالتعويض، وكان تفاقمه في المستقبل مقدرا، إنما لم تكن معطاتيه تتيح تقدير التعويض عنه مسبقا، فهنا لا يكون للمضرور حق المطالبة باستكمال التعويض، إلا إذا احتفظ لنفسه بذلك، ولو لم يتضمن الحكم إشارة لذلك التحفظ إذ أن العبرة بما هو ثابت في طلبات المدعي
- ✓ أما الصورة الثانية فهي التي لا يكون فيها الضرر الأصلي قد تفاقم، وإنما اقتضى مصاريف إضافية، ففي هذه الحالة أيضا لا يكون للمحكوم له بالتعويض أن يطالب بالمصاريف التي أنفقها بعد الحكم، لأن التعويض عن الضرر الأصلي كما تحقق، قد حدده الحكم نهائيا لأن القاضي عند تقديره للتعويض قد استعرض الضرر وأثره فعين التعويض عنه بمبلغ أدخل في حسابه كل المعطيات التي يستلزمها هذا التعيين

أما إذا كان الضرر غير متوقعا وقت الحكم بالتعويض، بمعنى أن القاضي لم يدخله في حسابه عند تقديره، وتكشفت الظروف عنه، ففي هذه الحالة يكون للمضرور حتى ولو لم يحتفظ له بحق المطالبة باستكمال التعويض، أن يطالب بالتعويض عما حدث من أضرار بعد الحكم، وذلك بدعوى جديدة، ولا محل للدفع بقوة الشيء المقضي به، لأن موضوع الدعوى الثانية غيره في الدعوى الأولى

*** الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي:**

ينبغي التمييز بين الضرر المستقبل وهو الذي يستوجب التعويض، وبين الضرر المحتمل وهو لا يكفي لاستحقاق التعويض. فالضرر المحتمل هو ضرر لم يقع، ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع، فيتوقف وقوعه

على ظرف غير مؤكد، فهذا النوع من الضرر لا يمكن أن يكون محلاً لتعويضه. إذ أنه ضرر افتراضي، ولا تبني الأحكام على الافتراض.

وقد يصح التمييز أحيانا بين ما يعتبر ضررا محققا، وخاصة إذا كان مستقبلا، وبين ما يعتبر ضررا احتماليا، ويقصد بذلك أن يتسبب شخص بخطئه في تضییع فرصة على الآخر، مثال ذلك حرمان طالب من دخول امتحان أو موظف من دخول مسابقة للترقية. ففي هذه الاحوال يكون هناك كسب احتمالي، كان يمكن لأن يتحقق، كما كان يمكن أن لا يتحقق، وجاء الفعل الضار وقضى على تحققه. فيكون الضرر الاحتمالي غير موجب للتعويض ذلك أن الكسب الذي فات لم يكن سوى مجرد أمل غير مؤكد تحققه

ثالثا: أن يكون الضرر مباشرا

يكون الضرر إما مباشرا أو غير مباشر، والضرر المباشر إما أن يكون متوقعا أو غير متوقع

القاعدة في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية أنه لا تعويض عن الضرر غير المباشر، بل يقتصر على الضرر المباشر فقط، ذلك أنه في المسؤولية التقصيرية يعوز عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، أما في المسؤولية العقدية فالأصل أن يقتصر التعويض على الضرر المباشر المتوقع وحده. ولا يمتد إلى الضرر غير المتوقع، إلا إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى غش المدين أو خطئه الجسيم

1- الضرر المباشر والضرر غير المباشر: الضرر المباشر هو ذلك الذي ينشأ عن الفعل الضار، بحيث أن وقوع هذا الفعل يؤدي حتما إلى ترتب هذا الضرر ويكون كافيا لحدوثه، وهذا ما يستشف من نص المادة 182 التي جاء فيها "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به"

فالضرر المباشر هو نتيجة طبيعية للفعل الضار ويعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول. والمقصود بأن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أن يكون متصلا اتصالا واضحا بالفعل الضار، وأن يأتي كنتيجة ضرورية للفعل في ظرفه وتسلسل وقائعه.

وإذا كان هذا التعريف للضرر المباشر يسمح بتبنيه بسهولة، فإن الضرر غير المباشر قد يعسر تحديده. فالضرر غير المباشر هو الذي يحدث نتيجة للفعل الضار الاصلي، دون أن يتصل به مباشرة،

فيكون الفعل الاصلي عاملا لازما لحصول الضرر، ولكن لا يكون وحده كافيا لحدائه، وإنما تتدخل أسباب أخرى . ومثاله أن يتسبب حادث في إصابة شخص بعاهة، فيندفع إلى الانتحار لينهي حياته، فالانتحار نتيجة غير مباشرة للحادث ذلك انه ليس كل من اصيب بعاهة ينتحر بالضرورة

2/. الضرر المتوقع وغير المتوقع: يعوض في المسؤولية التقصيرية عن كل ضرر مباشر، متوقعا كان أو غير متوقع، أما في المسؤولية العقدية، فلا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع ، ما عدا في حالي الغش والخطأ الجسيم فقد نصت المادة 182 ق.م. في فقرتها الاخيرة على انه "غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

الفقرة الرابعة: أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مالية مشروعة

ويقصد بمساس الضرر لحق ثابت للمضرور أنه لا يمكن مساءلة المعتدي إلا إذا مس اعتداؤه بحق ثابت يحميه القانون، سواء كان هذا الحق ماليا، مدنيا أو سياسيا.

وحتى ولو كان الضرر مرتدا على النحو الذي سبق شرحه، كانقطاع نفقة الاب عن ابنه، نتيجة إصابته بضرر أقعده عن العمل، فهذا الضرر لاحق بالحق في النفقة .

وقد يخل الضرر بمجرد مصلحة مالية، لا ترقى لاعتبارها حقا ، كأن يفقد شخص عائله دون أن يكون له حق ثابت في النفقة كما هو الحال للابن، فقد يكون من أحد أقارب العائل وهذا الاخير ينفق عليه دون أن يلزمه القانون بذلك، فهذا الفقد يجعل المعال قد أصيب في مصلحة مالية له.

ويشترط أن تكون المصلحة مشروعة للتعويض عنها، فإذا كانت غير مشروعة فلا يعتد بها، فلا يمكن تعويض الخليفة على فقد خليلها الذي كان يتولى الانفاق عليها، لان هاته المصلحة تقوم على علاقة غير مشروعة

الفقرة الرابعة: إثبات الضرر

الضرر أمر مادي، ومن ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وفقا لما تقض به القاعدة العامة " البيئة على من ادعى" وإثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع، ولا رقابة فيها للمحكمة العليا. أما تحديد الضرر وبيان عناصره

وموجباته وتكييف نوعه، كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأئ مسائل قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.

المبحث الثالث: علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر

علاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الفعل الضار الذي ينسب الى المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالضحية. وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة "ويسبب ضررا". وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يكسرها باثبات السبب الاجنبي، أي السبب الذي لا يد له فيه

الفرع الاول: تحديد السببية

ولقيام المسؤولية المدنية، لابد أن يكون الفعل الضار هو السبب المباشر في حدوث الضرر. وهذا الامر بالغ الاهمية لتحديد السببية عند تعدد اسباب الضرر او عند تعاقب الاضرار، أي لما يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث ... (الفقرة الاولى)

. هذا ومن الضروري كذلك تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى : تعدد الاسباب

قد يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد احد منها كون الضرر وقع باجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقتها شخص قاصر وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شيخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟ ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الاسباب خاصة في الفقه الالماني ومن أهمها:

اولا: نظرية تكافؤ الاسباب أو تعادلها : كل من ساهم في احداث الضرر هو سببه

عرفها الفقيه فون بوري vonburi بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين الفعل والاثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر. ولمعرفة ما إذا كان هذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركته فإذا كان الجواب بالايجاب اعتد به ،

وان كان الجواب بالنفي فلا تقوم العلاقة السببية ولا يعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج

ثانيا: نظرية السبب المنتج : السبب الذي من الطبيعي والمتوقع ان يحدث الضرر

رائد هذه النظرية هو الفقيه الالماني "فون كريس". و مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الاسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الاسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للامور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون.

ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 ق.م. تؤيد فكرة النظرية.

الفقرة الثانية : تعاقب الاضرار

يحدث ذلك عندما يؤدي الفعل إلى ضرر ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الاخير يؤدي إلى ضرر ثالث ... وهكذا. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات. فهل يسأل بائع البقرة على كل هذه الاضرار أم إن هناك نقطة يجب ان نقف عندها.؟

ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، فلا يسأل البائع الا عن المشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الاضرار لا يسأل عنها.

الفرع الثاني : إثبات السببية

ان رابطة السببية ركن مستقل، والخطأ ركن مستقل والضرر ركن مستقل أيضا، ومن هنا فإن من يدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا بما فيها رابطة السببية.

هذا وكما رأينا، قد يفترض المشرع علاقة السببية كلما افترض الخطأ. كما يمكن للقضاء كذلك افتراض السببية من خلال القرائن القضائية

الفرع الثالث : نفي السببية – السبب الاجنبي

تنص المادة 127 ق.م على أنه: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب لا بد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".

نفي السبب الاجنبي هو نفي المسؤولية



فإذا تدخل السبب الاجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا عن الضرر

فالمقصود بالسبب الأجنبي عن المدعى عليه هو كل فعل أو حادث لا ينسب إلى المدعي عليه، ويكون هو السبب في احداث الضرر ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلا، ويظهر من هذا التعريف أن للسبب الأجنبي ركنين هامين وهما:

✓ يجب ان يستحيل على المدعى عليه استحالة مطلقة أن يتصرف بخلاف ما فعل: ويتم تقدير هذه الاستحالة بمعيار موضوعي مجرد، وهو معيار الرجل المعتاد بمثل الظروف التي وجد بها المدعى عليه

✓ لا بد أيضا أن يكون الحادث خارجا عن إرادة المدعى عليه، وألا يمكن إسناده إليه بأي حال.

هذا ولا يكون الحادث سببا أجنبيا إلا إذا استوى ثلاثة شروط، وهي : عدم إمكان درء نتائجه - غير متوقع الحصول - وغير ممكن تلافيه.. ويتمثل السبب الاجنبي بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية:

الفقرة الاولى: القوة القاهرة والحادث المفاجئ:

لقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، ولقد اجمع جمهور الفقهاء على عدم التمييز بينهما، بحيث بهما نفس الشروط ونفس الاثار، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع، بالاضافة إلى أن القانون يعطي لهما نفس الحكم من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من إقامة علاقة السببية، لكن يمكن التمييز بينهما على اساس ان الحادث المفاجئ الظرف الطارئ هو حدث عام يمس كل المجتمع او فئة كبيرة منه الازمات الاقتصادية والابوئة والكوارث الطبيعية و الامنية يستحيل توقعه ويستحيل دفعه ... و يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا على

المدين وليس مستحيلا... اما القوه القاهرة فهي كذلك كرف طارى لكن لا يمس كل المجتمع بالضرورة و انما المدين وحده كالأفلاس و المرض والحادث ... يستحيل كذلك توقعها و دفعها ... و تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وليس فقط مرهقا

وعلى كل حال، كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة كسبب أجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان

الشرط الاول : عدم إمكان التوقع : وإذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة

الشرط الثاني : استحالة الدفع : فإذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة . ويشترط كذلك إن يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية أو معنوية مثلا توفي شخص عزيز تجعل المدين غير قادر على تأدية التزامه.

الفقرة الثانية: خطأ المضرور

ويقصد هنا ان المدعي هو من وقع منه الفعل الضار. ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ إذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي .

لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟

اولا يجب التفرقة بين الخطأين إما إن يكون احد الخطأين يستغرق الآخر، وإما إن يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك. ففي حالة استغراق أحد الخطأين الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه، لكنها تقوم إذا وقع العكس.

أ. يكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين:

الاولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة: فتكون صورتان

1. أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة

2. رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلاً أن يقبل صاحب الباخرة بنقل سلع إلى بلد تحرم قوانينها تلك السلع ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفاً بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذ أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن

والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر: هنا يجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولاً ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لأن الأول يجب الخطأ الثاني،

ب. وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة أكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس. المادة 177 ق.م. : "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

الفقرة الثالثة : خطأ الغير:

إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال إذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الأشكال يثور حول ما إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول أو خطأ المضرور. فإذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما إن يستغرق أحد الآخر الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير). أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير. وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.

وإذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه. وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض

المحور الثاني :

اثار المسؤولية التقصيرية : التعويض

التعويض هو الجزاء الذي اسس نظام المسؤولية المدنية لاجله. و الهدف من التعويض هو اصلاح او جبر الضرر الناتج عن الفعل المنسوب للمسؤول و ليس عقابا لهذا الاخير، بالتالي ينشأ الحق في التعويض وقت حدوث الضرر وليس وقت الحكم به

يتولى القاضي من خلال الحكم، بعد تحديد المسؤول، تحديد طبيعة التعويض عيني ام نقدي، وتعيين مقداره، فيصبح مستحق الاداء ويصبح الحكم القضائي بمثابة سند تنفيذي يسمح للمضرور مباشرة التنفيذ الجبري على اموال المسؤول عند الحاجة وله المطالبة باجراءات تحفظية او تنفيذية

ولما كانت المسؤولية التقصيرية من النظام العام فيعد كل شرط للاعفاء منها باطل بطلان مطلق (م. 178 ق.م.)، فلا يجوز مثلا للمتبوع عند تعامله مع زبائنه ان يشترط عليهم اعفاؤه من المسؤولية عن افعال تابعه.. هذا ويقع الاتفاق باطلا اذا تم قبل وقوع الضرر ، لكن يجوز للضحية التنازل عن حقها بعد وقوع الضرر، كما يجوز الاتفاق على ميلق يفوق مبلغ التعويض

يتقادم الحق في التعويض بمرور 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار (م. 133 ق.م.). وتتقادم السندات التنفيذية التي تثبت الحق في التعويض بمضي 15 سنة من تاريخ قابليتها للتنفيذ.

الفرع الاول : طريقة التعويض

تنص المادة 132 ق.م. " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، أما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا. ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض ، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع."

يتبين من النص أن التعويض إما أن يكون بمقابل وهذا هو الاصل العام، أو أن يكون عيناً بطلب من المضرور وحسب الظروف

1- التعويض بمقابل: وهو التعويض النقدي

يهدف التعويض بمقابل إلى جبر الضرر. وقد يكون المقابل في هذا التعويض نقدًا أو غير نقدي. والتعويض غير النقدي غالباً يحكم به لجبر الضرر الادبي . كحق الرد مثلاً، ولكن يبقى التعويض النقدي هو الاصل في دعوى المسؤولية التقصيرية. ويحكم القاضي به عندما يتعذر الحكم بالتعويض العيني، أو عندما لا يطلب المضرور التعويض العيني.

والاصل في التعويض النقدي أن يكون مبلغاً نقدياً يدفعه المدعى عليه مرة واحدة للمضرور. ولكن أجازت المادة 132 للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي مقسط، أو إيراد مرتب مدى الحياة لا سيما في حالة الضرر المستمر. كما لو أدى الفعل الضار إلى عجز المضرور عن العمل كلياً.

2- التعويض العيني:

يكون التعويض العيني بطلب من المضرور وحسب الظروف وذلك كالآتي:

1. إما إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر: وهذا التعويض يحكم به القاضي في الحالات التي يستمر فيها الضرر مستقبلاً ← وقف الاعتداء.
2. إما القيام بأداء معينة: يحكم القاضي بهذه الاداءات على سبيل التعويض اذا كانت إعادة الحالة الى ما كانت عليه تضر بمصالح المسؤول

الفرع الثاني: تقدير التعويض

تنص المادة 182 ق.م.: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب...."

يفهم من خلال النص ان تقدير التعويض يخضع لمبدأ التكافؤ بين التعويض والضرر فلا فيقدر على اساس ما لحق المضرور من ضرر وما فاتها من كسب جراء الفعل الضار

وإذا أستطاع المضرور إثبات الضرر فإنه يتمتع بحرية تامة في ملكية التعويض فيجوز أن تقع على هذا التعويض اتفاقات تحدد معالم المسؤولية المدنية متضمنة زيادة في التعويض أو إنقاصه أو التنازل عنه وهذا ما نسميه التعويض الاتفاقي ، أو أن يلجأ المضرور للقضاء ونسميه تعويضاً قضائياً ، أو أن يتولى القانون بنفسه في حالات محددة تحديد معالم التعويض ونسميه تعويضاً قانونياً . على ان

تظل العبرة في تقييم التعويض بالضرر وليس مركز الخصوم. بالتالي فلا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض (مثلا من المسئول + شركة التأمين + صندوق الضمان الاجتماعي...) واحد الا اذا كانت اسس المسؤولية تختلف .